

السؤال

الصفحة

ص: ٢	س ١: عرف القانون الدولي الخاص مبيناً أهم الموضوعات التي يتناولها؟
ص: ٤	س ٢: اشرح مصادر القانون الدولي الخاص؟
ص: ٧	س ٣: عرف قواعد التنازع مبيناً أركانها؟
ص: ٨	س ٤: عرف التكييف مبيناً أهميته ونطاق نظرية بارتان في التكييف وموقف المشرع المصري من مشكلة التكييف؟
ص: ١٢	س ٥: عرف المقصود بالإحالة وصورها وما هو موقف المشرع المصري منها؟
ص: ١٩	س ٦: وضع القانون الواجب التطبيق بشأن الاهلية؟
ص: ٢١	س ٧: وضع القانون الواجب التطبيق بشأن الشروط الموضوعية للزواج؟
ص: ٢٤	س ٨: وضع القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والفريق والنفقة والميراث والوصية؟
ص: ٢٦	س ٩: وضع اثر النظام العام علي القانون الواجب التطبيق علي الميراث والوصية؟
ص: ٣٠	س ١٠: اكتب في الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من القانون المقارن؟
ص: ٣١	س ١١: اكتب في حالات الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من طبيعة النزاع؟
ص: ٣٤	س ١٢: ما هي حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالميراث؟
ص: ٣٥	س ١٣: وضع أهمية الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها؟
ص: ٣٦	س ١٤: اكتب في الشروط الموضوعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية؟
ص: ٣٨	س ١٥: اكتب في الشروط الشكلية لتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر؟
ص: ٤٦	س ١٦: يشترط لتنفيذ الحكم او الامر الاجنبي في مصر عدم التعارض مع النظام العام . وضع ذلك؟
ص: ٥٠	س ١٧: وضع اجراءات دعوي تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر؟

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي

س ١ : عرف القانون الدولي الخاص مبيناً أهم الموضوعات التي يتناولها؟

تعريف القانون الدولي الخاص

يختلف تعريف القانون الدولي الخاص باختلاف المذاهب الفقهية :

الرأي الأول ← من الفقهاء من يدخل القانون الدولي الخاص ضمن نطاق مسائل الجنسية والمواطن وتنفيذ الأحكام الأجنبية

الرأي الثاني ← ذهب بعض الفقهاء في إخراج تعريف القانون الدولي الخاص من نطاق احدي هذه المسائل .

الرأي الغالب ← القانون الدولي الخاص يدرس ستة مواضيع هي (تنازع القوانين , تنازع الاختصاص , حالة الأجانب , الجنسية , المواطن , تنفيذ الأحكام , الأوامر الأجنبية)

من هنا يمكن تعريف القانون الدولي الخاص

مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي والتي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي وحالة الأجانب والجنسية والمواطن وتبين كيف يمكن تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية

صلة القانون الدولي الخاص بفروع القانون الأخرى

أ- يشبه القانون الدولي الخاص القانون الدولي العام ← من ناحية العلاقة القانونية فيهما تجاوز إقليم الدولة الواحدة إلى إقليم آخر، وفي أن المعاهدات الدولية هي مصادر كلا القانونين، إلى جانب العرف الدولي والقضاء الدوليين .

ب- لكن القانونين يتميزان عن بعضهما - من ناحية - أن قواعد القانون الدولي العام تتوجه بالخطاب إلى الدول باعتبارها أشخاص من أشخاص القانون الدولي العام، بينما قواعد القانون الدولي الخاص تتوجه بالخطاب إلى أشخاص القانون الخاص، أي إلى الأفراد أو الأشخاص المعنوية التي يعرفها القانون الداخلي. كما يتميز القانونان عن بعضهما بأن قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية، ليست صادرة عن سلطة تشريعية في دولة معينة، وهي لم تقترن حتى الآن بجزء يوقع على من يخالفها، بينما قواعد القانون الدولي الخاص قواعد قانونية داخلية ملزمة، بمعنى أنها تصدر في الغالب عن السلطة التشريعية داخل الدولة وتقترن بجزء توقعه السلطة العامة على من يخالفها.

موضوعات القانون الدولي الخاص

أ- هناك موضوع متفق بالإجماع على أنه من مسائل القانون الدولي الخاص وهو موضوع تنازع اسوانين،

البحث عن القانون الواجب التطبيق، حينما يكون النزاع المعروض مشتملاً على عنصر أجنبي فلو أشتري مصري عقاراً أو منقولاً موجوداً بإيطاليا ورفع عن هذا العقد نزاع فعلي القاضي الذي عرض عليه أن يبحث ما هو القانون الواجب التطبيق علي هذا العقد أهو القانون المصري أم القانون الإيطالي ؟

لو توفي إيطالي بمصر وقد ترك وصية رفع عنها نزاع أمام القضاء المصري فعلي هذا القضاء أن يبحث عن القانون الواجب التطبيق سواء من حيث الشروط الشكلية أو من حيث الشروط الموضوعية لهذه الوصية ؟ أهو القانون الإيطالي أم هو القانون المصري .

علي ذلك فمعني تنازع القوانين ان يكون هناك قانونان او اكثر يمكن ان تحكم النزاع المعروض علي القضاء فيجري البحث عن اي القوانين يجب تطبيقه عليه .

ب- تنازع الاختصاص:

الموضوع الثاني الذي تتفق أغلبية الفقه على إدخاله في نطاق القانون الدولي الخاص، هو موضوع تنازع الاختصاص، أو **البحث عن المحكمة المختصة دولياً** بالنظر في النزاع والواقع هو ان هذه المسألة يجب ان تعرض قبل مسألة تنازع القوانين فلكي يحدد القاضي المعروض عليه النزاع ما هو القانون الواجب التطبيق علي هذا النزاع يجب عليه أولاً ان يبحث عما إذا كان هو نفسه مختصاً او غير مختص بالنظر في هذا النزاع فإذا كانت محكمته مختصة بالنظر فيه انتقل بحثه الي القانون الواجب التطبيق علي هذا النزاع .

موضوع تنازع الاختصاص اذن مسألة اولية ومسألة تحديد اختصاص المحاكم داخل كل دولة مسألة يستأثر المشرع الداخلي وحده بحلها فكل دولة تحدد في قانون المرافعات متى تكون محاكمها مختصة بالنظر في نزاع يشتمل علي عنصر اجني دون ان تتعرض لاختصاص المحاكم الاجنبية .

مسألة تنازع الإختصاص ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة تنازع القوانين وتؤثر كل منهما في الأخرى إذ أن مسألة تنازع القوانين لا تنشأ إلا إذا رأي القضاء تطبيق القانون الأجنبي ولهذا الإعتبار فإن أغلبية الفقهاء تجعل موضوع تنازع الإختصاص من بين موضوعات القانون الدولي الخاص .

ج- تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية:

هذا موضوع ثالث يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص، لاتصاله بمسألة الاختصاص القضائي وبما أن الأحكام القضائية تكون إما منشئة أو كاشفة للحقوق فقد أجازت قواعد القانون الدولي الخاص تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ببعض الشروط إعمالاً لما تكشفه الأحكام أو تنشئه من الحقوق الخاصة ولذلك أدخل هذا الموضوع في نطاق القانون الدولي الخاص .

د- مركز الاجانب :

هذا موضوع رابع تدخله أغلبية الفقه ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص، بل تعتبر هذه المسألة **مسألة أولية** تعرض للبحث قبل البحث عن مسألة تنازع القوانين لأنه لا يتصور البحث عن القانون الواجب التطبيق علي النزاع المعروض إلا بعد البحث عما إذا كان الأجنبي الذي هو طرف في النزاع يتمتع أو لا يتمتع بالحق محل النزاع وإذا قضي بعدم تمتعه بهذا الحق فإن مسألة تنازع القوانين لا تعرض علي الإطلاق .

ذلك ان الدول لا تمنح للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها فتحرم بعضها علي الاجانب تملك العقارات في اقليمها وقد تحرم بعضها علي الاجانب ممارسة بعض المهن الهامة كالمحاماة او الطب كما ان الاجانب محرومون من ممارسة الحقوق السياسية وتختلف سياسة الدول اختلافاً بيناً في مدي ما يمنح للأجانب من حقوق .

هـ- مسألة الجنسية:

هذا موضوع خامس يدخله الفقهاء ذوو النزعة اللاتينية في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص، ويبررون وجهة نظرهم هذه بأن **الجنسية**، وهي الرابطة التي تربط الفرد بدولة معينة هي التي تميز بين الوطني والأجنبي فيجب علي القاضي أن يبحث أولاً عما إذا كان هذا الشخص أجنبياً أو وطنياً أي أن يفصل في مسألة الجنسية الخاصة بهذا الشخص .

فضلاً عن ذلك فإن المذهب اللاتيني يربط بين جنسية الشخص وبين حالته وأهليته **فطبقاً لهذا المذهب** ينبغي من اجل الوصول إلي حل في مسألة تنازع القوانين الرجوع إلي قانون جنسية الشخص الذي هو طرف في النزاع وبالتالي يكون الفصل في مسألة الجنسية سابقاً للفصل في مسألة تنازع القوانين إذا تعلق الأمر بحالة الشخص أو اهليته .

يؤيد الفقهاء اللاتينيون وجهة نظرهم هذه فوق ذلك بقولهم ان الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنظر في الدعاوي التي تشتمل علي عنصر اجني يتحدد في اغلب الأحوال بجنسية الخصوم وكثير من الدول لا تكتفي بشرط ان يكون المدعي وحده وطنياً حتي يكون الاختصاص لمحاكم الدولة بل تشترط فوق ذلك ان يتصل النزاع بالدولة سواء بالنسبة إلي المدعي عليه او بالنسبة إلي عناصر النزاع الأخرى .

للكل هذه الاعتبارات يرى الفقهاء اللاتينيون ان هناك صلة وثيقة بين مسألة الجنسية ومسألة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص وان المسألة تعتبر احد موضوعات القانون الدولي الخاص .

و- الموطن:

إذا كان الرأي السائد هو إدماج مسألة الجنسية ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص فيجب أن يدرس الموطن إلي جانب الجنسية .

هذه هي المسائل الست التي يعتبرها اغلب الفقهاء مكونة لموضوعات القانون الدولي الخاص ولو شئنا ان نلخص هذه المسائل لقلنا انها تنحصر في موضوعات ثلاثة :

٣-نفاذه

٢-استعماله

١- اشخاص الحق.

أشخاص الحق ← موضوع الجنسية والموطن ومركز الأجانب استعمال الحق يدرس في تنازع القوانين ونفاذ الحق يدرس في تنازع الاختصاص القضائي وفي تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية .

س ٢: اشرح مصادر القانون الدولي الخاص؟

مصادر القانون الدولي الخاص

أ-المصادر الدولية:

١- **الاتفاقيات الدولية** ← هناك اتفاقات تعقد بين دولتين فأكثر لتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص .
نلاحظ مثلاً ← ان مصر قد عقدت اتفاقيات ثنائية مع كثير من الدول لتنظيم بعض هذه المسائل كما انها طرف في بعض المعاهدات الجماعية التي تناولت مسائل القانون الدولي الخاص .
 اهم الاتفاقيات في هذا الصدد هي **اتفاقية جنيف الخاصة بحق المؤلف** والصادرة في سنة (١٩٥٢) ثم نظمت كذلك باتفاقيات دولية مسائل الملاحة البحرية والجوية ومسائل المواصلات البرية ومسألة الأوراق التجارية ومسألة التحكيم ومسألة النفقة الواجبة للأقارب واهم اتفاقيات دولية عقدت لتنظيم مسائل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي هي **اتفاقيات لاهاي** .
 ان للقانون الدولي الخاص مصادر داخلية سوف نعرض لها فيما بعد وأهمها **التشريع** فقد يحدث ان يصدر تشريع داخل الدولة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية فماذا يكون موقف القاضي إزاء هذا التعارض ؟ لا تخلو الحال من احد الفرضين :

أ-الفرض الأول

ان تكون المعاهدة لاحقة للتشريع الداخلي فهنا يمكن ← القول بأن أحكام المعاهدة تنسخ أحكام التشريع الداخلي نسخاً ضمناً فيما تعارضت معه فيه .

قد يعترض علي ذلك بأن المعاهدات من عمل السلطة التنفيذية فيكيف تلغي تشريعاً داخلياً صادراً عن السلطة التشريعية ؟
 من السهل الرد علي هذا الاعتراض إذ أن الدساتير تفوض إلي السلطة التنفيذية سلطة المعاهدات فكأن المعاهدات بناء علي هذا التفويض صادرة من السلطة التشريعية .
 فضلاً عن هذا فإن التصديق علي المعاهدات يتم بواسطة السلطة التشريعية فيفترض ان هذه السلطة بتصديقها علي المعاهدات وقد وافقت ضمناً علي إلغاء ما يخالف أحكامها من تشريع داخلي .

ب-الفرض الثاني

ان يصدر تشريع داخلي يتعارض مع أحكام معاهدة سابقة ← قد يحدث ذلك علي الرغم من مخالفته للعرف الدولي ولكن قضاء محكمة العدل الدولية يقضي علي سمو أحكام المعاهدات وبالتالي فإن احكام المعاهدات ملزمة للدولة الموقعة عليها دون اعتبار لما يخالف هذه الأحكام في التشريع الداخلي .

التعارض بين أحكام المعاهدات وبين التشريع الداخلي في القانون المصري :

لم يرد بالدستور المصري نص يغلب أحكام المعاهدات علي أحكام القانون الداخلي سواء كان سابقاً أو لاحقاً غير أن القانون المدني المصري ينص علي عدم سريان أحكام المواد الخاصة بتنازع القوانين إذا تعارضت مع أحكام معاهدة دولية نافذة في مصر .

لكن هذا النص لم يتعرض لحكم ما إذا كانت المعاهدة لاحقة للقانون المدني وفي هذه الحالة لا مناص من الأخذ إذن بما ذكرناه في الفرض الأول .

لقد كان قانون المرافعات المصري أكثر صراحة حين نص في المادة (٤١١) منه علي عدم اخلال النصوص الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن فهذا النص قطع صراحة بتطبيق أحكام المعاهدات الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية دون أحكام قانون المرافعات المصري سواء كانت هذه المعاهدات سابقة أو لاحقة لقانون المرافعات.

تفسير المعاهدات :

قد يصدر تفسير النصوص الغامضة في المعاهدات من الدولتين أو الدول التي وقعتها فيكون هذا التفسير ملزماً لكل الأطراف كالمعاهدة نفسها وقد يتم هذا التفسير في شكل ملحق ؟ أو في شكل كتب متبادلة بين الأطراف المعنية وقد يصدر التفسير من القضاء الدولي إذا عهدت إليه الدول المتعاقدة في المعاهدة بذلك فيكون ملزماً أيضاً للأطراف المعنية .

٢- **العرف الدولي** ← المصدر الدولي الثاني لقواعد القانون الدولي الخاص هو العرف الدولي، وقد انكر بعض الشراح وجود عرف دولي ملزم في نطاق القانون الدولي الخاص ومع ذلك يري فريق آخر من الشراح ان في هذا القانون بعض القواعد المستمدة من العرف الدولي المستقر من عهد طويل مثل قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون المحل وقاعدة خضوع العقار لقانون موقعه.

٣- **القضاء الدولي** ← بما ان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يقضي بأن للدول وحدها الحق في التقاضي امام هذه المحكمة وربما ان منازعات القانون الدولي الخاص تنشب بين الأفراد وليس لهؤلاء الحق في التقاضي امام هذه المحكمة فلذلك كان قضاء محكمة العدل الدولية في نطاق القانون الدولي الخاص من النادرة بحيث لا يمكن ان يعتبر مصدراً هاماً من مصادر هذا القانون . فهناك أحكام قليلة صدرت سواء من المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو من محكمة العدل الدولية التي خلفتها، قررت مبادئ في مسائل الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي.

٤- **الفقه الدولي** ← لقد ساهم الفقه الدولي بقسط كبير في تكوين قواعد القانون الدولي الخاص.

مثال ذلك ← فقد المدارس الايطالية والمدرسة الهولندية

ب-المصادر الداخلية :

تعتبر مصادر القانون الدولي الخاص الداخلية هي ذات مصادر القانون الداخلي. قد نصت **المادة الأولى** من القانون المدني المصري. على أن **هذه المصادر هي التشريع ثم العرف ثم مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم القانون الطبيعي وقواعد العدالة .**

فيما يتعلق بمركز الأجانب في مصر ← فقد كفل الدستور للأجانب حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان مع عدم الإخلال بالنظام العام والأداب ونص علي عدم إبعاد الأجانب إلا طبقاً لأحكام القانون .

صدر قانون بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ثم قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر كما صدر قانون يحظر تملك غير المصريين للعقارات ثم صدرت تشريعات مختلفة تحرم علي الأجانب إمتهان بعض المهن في مصر مثل مهنة المحاماة ومهنة الطب وذلك إلي جانب قوانين الإستثمار المتعاقبة .

ترتيب المصادر السابقة:

علي القاضي المصري اذا عرضت عليه قضية تنازع فيها القوانين ان يبحث عما اذا كان هناك قانون خاص صدر في مصر وتناول حكم المسألة او كانت هناك معاهدة دولية نافذة في مصر فيطبق احكام المعاهدة دون احكام القانون الداخلي وذلك طبقاً لنص المادة ٢٣ من القانون المدني التي تقضي بتطبيق احكام القانون الخاص او احكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر قبل تطبيق احكام التنازع الداخلية فإذا لم يكن هناك قانون خاص ولا معاهدة انتقل القاضي الي تطبيق احكام تنازع القوانين الواردة في المواد من ١٠ الي ٢٢ فإذا لم يجد الحكم في هذه المواد وجب تطبيق نص المادة ٢٤ مدني التي تقضي بالرجوع الي مبادئ القانون الدولي الخاص وهذه المبادئ مستمدة من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فإن لم تسعفه هذه المبادئ انتقل الي العرف الداخلي واذ لم يجد الحكم فيه بحث في الشريعة الاسلامية ثم بمبادئ القانون الطبيعي والعدالة ثم العرف الدولي ثم القضاء والفقه الدوليان

تنازع القوانين - مقدمة لدراسة التنازع

ما المراد بتنازع القوانين، الذي يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص؟

هناك عدة أنواع من التنازع بين القوانين:

النوع الأول : تنازع بين القوانين من حيث الزمان، وتنازع بين القوانين من حيث المكان، فالأول يعرض حين تتعاقب القوانين الداخلية في إقليم دولة ما على واقعة قانونية مستمرة، فيجب البحث عن أي القوانين يحكم هذه الوقائع أو يحكم آثارها.

بينما تنازع القوانين من حيث المكان، يعرض حين يتعاقب على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي قانونان أو أكثر، صادران من دولتين فأكثر، وهذا التنازع هو الذي يدرس في القانون الدولي الخاص.

النوع الثاني :ويقتصر التنازع المكاني المذكور، على التنازع بين القوانين المدنية أو التجارية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية.

النوع الثالث : قد يحدث تنازع بين القوانين الداخلية في الدولة البسيطة أو في الدولة المركبة، وهو غير التنازع بين القوانين الدولية.

النوع الرابع : تنازع بين القوانين للبلاد المستعمرة وقوانين المستعمرات ترتب علي أثرها ما كان يسمى بالإمتيازات الأجنبية التي زالت الآن .

التنازع في القانون الدولي الخاص :

إذن، فالتنازع الذي يعالجه القانون الدولي الخاص، يمكن أن يعرف بأنه تزامن قانونين فأكثر، لدولتين أو أكثر، بشأن حكم علاقة قانونية، تشتمل على عنصر أجنبي.

فلكي يقوم التنازع يجب أن نكون بصدد علاقة قانونية تشتمل علي عنصر أجنبي أي أن يكون الأطراف فيها أجنب أو يكون موضوعها أو سببها أجنبياً .

علي ذلك فلكي يقوم التنازع بين القوانين يجب أن تتوافر الشروط الآتية :

- ✓ **أولاً :** أن تمتد العلاقة القانونية المعروضة إلي أقاليم أكثر من دولة .
- ✓ **ثانياً :** أن يكون المشرع الذي يعرض النزاع أمام محاكمة قد أفسخ المجال لتطبيق القانون الأجنبي إذ لو اعتنق كل مشرع مبدأ إقليمية القوانين إقليمية مطلقة ما كان هناك مجال لتطبيق قانون أجنبي وبالتالي للتنازع .
- ✓ **ثالثاً :** أن تكون القوانين التي يمكن أن تحكم العلاقة القانونية المعروضة مختلفة في أحكامها إذ لو كانت أحكامها موحدة ما كان محل لقيام تنازع بينها

نظور مسألة تنازع القوانين :

كانت الجماعات القديمة، لا تقبل دخول أجنبي إقليمها ولا تتعامل مع غيرها، وقد رأينا أن روما لم تعرف تنازع القوانين بالمعنى الذي ندرسه. ولم تظهر مشكلة التنازع إلا في نطاق ضيق بين المدن الإيطالية. وفي هذه البيئة الإيطالية، نشأت نظرية الأحوال، غير أن فقهاء هذه المدرسة، لم يتعرضوا لمسألة التكييف، التي يرجع الفضل في تأصيلها إلى الفقيه الفرنسي بارتان.

تعريف قاعدة التنازع وأركانها

س ٣: عرف قواعد التنازع مبينا أركانها؟

أولاً: تعريف قاعدة التنازع

قاعدة قانونية وضعية ذات طبيعة فنية، تطبق على العلاقات الخاصة الدولية، لتصطفى أكثر القوانين مناسبة وملائمة لتنظيم هذه العلاقات، حينما تتعدد هذه القوانين لحكم هذه العلاقات.

ثانياً: مكونات قاعدة التنازع

العنصر الأول: الفكرة المسندة

لما كانت العلاقات التي تتضمن عنصر أجنبي لا يمكن حصرها، فقد تكفل المشرع الوطني في كل دولة بتصنيف تلك العلاقات وتقسيمها إلى فئات مختلفة، أطلق على كل فئة منها مسمى الفكرة المسندة بحيث تتضمن كل فكرة منها مجموعة من العلاقات المتقاربة أو المتشابهة . فوجدت فكرة (الأهلية - الشكل المال - العقد - الزواج - الطلاق)

العنصر الثاني: ضابط الإسناد

هو الأداة أو المعيار الذي يتخذه المشرع لتحديد القانون الواجب التطبيق على الفكرة المسندة، ويستمد من أحد عناصر العلاقة القانونية على النحو الذي يرى فيه المشرع أنه يمثل مركز الثقل في هذه العلاقة مثال ذلك خضوع حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم فإن ضابط الإسناد في هذه الحالة هو جنسية الأطراف .

العنصر الثالث : هو القانون الواجب التطبيق على الفكرة المسندة بمقتضى ضابط الإسناد

يعبر البعض عن موضوع تنازع القوانين باسم تنازع الاختصاص التشريعي الدولي والذي يبحث في مشكلة القانون الواجب التطبيق على العلاقات الخاصة الدولية بخلاف تنازع الاختصاص القضائي الدولي الذي يبحث في مشكلة المحكمة المختصة بنظر هذه العلاقات والاختصاص التشريعي مستقل ومنفصل عن الاختصاص القضائي ذلك أن المبدأ السائد لدى فقه القانون الدولي الخاص هو عدم التلازم بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي والذي مفاده أنه المحكمة المختصة بنظر النزاع يصح أن تكون محكمة أخرى خلاف محكمة الدولة التي يتم تطبيق قانونها على النزاع، كما أن القانون الواجب التطبيق على النزاع بواسطة محكمة معينة قد يكون قانون آخر خلاف قانون دولة المحكمة المختصة بالنزاع.

نبين أوجه التشابه والاختلاف بين قواعد التنازع وقواعد الاختصاص القضائي التي تتمثل في التالي:

١- الطابع الوضعي

قاعدة التنازع هي قاعدة وضعية أي إنها من وضع أو صنع المشرع الوطني في كل دولة، حيث يكون لكل دولة نظامها الخاص بتنازع القوانين وعند تعدد هذه النظم يلجأ القاضي الوطني إلى قواعد التنازع المنصوص عليها في قانونه الوطني لتحديد أحد الأنظمة وتطبيقها على المنازعات الخاصة الدولية.

٢-قواعد التنازع غير مباشرة وقواعد الاختصاص القضائي مباشرة

٣-قواعد التنازع هي قواعد غير مباشرة فهي لا تتضمن حلاً موضوعياً للنزاع إنما تحدد فقط القانون الواجب التطبيق على النزاع والذي يتضمن بداخله الحل الموضوعي له (فهي مجرد قاعدة وسيطة بين القاضي المختص والقانون واجب التطبيق على النزاع .

٤-قواعد التنازع ثنائية أو مزدوجة الجانب وقواعد الاختصاص القضائي منفردة أو أحادية الجانب قاعدة التنازع تنهض بمهمة تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، ويقصد بازدواجية هذه القاعدة إنها قد تشير إلى تطبيق القانون الوطني، وقد تشير إلى تطبيق قانون دولة أجنبية، وبالتالي فإن قاعدة التنازع تقدم الأساس المقبول لإمكانية تطبيق القانون الأجنبي على الإقليم الوطني للدولة الأمر الذي يعكس التسامح بين الأنظمة القانونية في تطبيق القوانين الأجنبية على إقليمها خروجاً على مبدأ الإقليمية المطلقة.

إذا كانت قاعدة التنازع مزدوجة الجانب على هذا النحو، فإن قواعد الاختصاص القضائي قواعد أحادية الجانب لا تحدد سوى اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات الخاصة الدولية ولا تحدد المحاكم الأجنبية المختصة في حالة عدم اختصاص المحاكم الوطنية للدولة وإلا اعتبر ذلك تعد على سيادة الدولة الأجنبية التي تحدد اختصاصها، حتى ولو على فرض ذلك فإن القاضي الوطني لا يأتزم إلا بأوامر مشرعه الوطني ولا يأتزم بأوامر مشرع أجنبي

تنازع القوانين

س ٤ / عرف التكييف مبيناً أهميته ونطاق نظرية بارتان في التكييف وموقف المشرع المصري من مشكلة التكييف؟

التكييف

أولاً: تعريفه وأهميته :

تفرض مشكلة التكييف نفسها على القاضي، ليس فقط في مجال القانون الدولي الخاص، ولكن في جميع فروع القانون الأخرى.

مثال ذلك في نطاق القانون المدني يواجه القاضي مشكلة التكييف، عندما يتصدى لتحديد وصف الرابطة العقدية المطروحة أمامه وصفاً قانونياً سليماً، لينتهي إلى ما إذا كان العقد محل النزاع عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة. وفي نطاق القانون الجنائي يواجه القاضي مشكلة التكييف، عندما يتصدى لوصف الفعل الذي ارتكبه المتهم، لمعرفة ما إذا كان يعتبر من قبيل السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة.

ثانياً: مرحلة التكييف :

مرحلة التكييف هي أول ما يعرض له القاضي عندما تقدم له مسألة تشتمل على عنصر أجنبي، إذ يجب عليه قبل كل شيء، أن يدخل العلاقة المعروضة عليه في نظام من النظم القانونية، حتى يعرف ما هو القانون الذي يستند إليه حكمها، أي أن **مرحلة التكييف تسبق بالضرورة مرحلة الإسناد.**

لقد عرف الفقهاء التكييف بأنه تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين، لوضعها في نطاق طائفة من النظم القانونية، لكي يسند حكمها إلى قانون معين.

الأمثلة الأتية توضح أهمية البحث في مسألة التكييف :

١- مات هولندي في فرنسا، وكان قد أجرى وصية بخط يده، وعرضت مسألة صحة هذه الوصية على القضاء الفرنسي، وتأسس الطعن في هذه الوصية على أن القانون الهولندي يحرم الوصية الخطية على الهولنديين ولو في الخارج. ويعتبر إجراء الوصية في شكل رسمي مسألة أهلية تتعلق بحماية الموصي. وتأسس دفاع الموصي له، على أن القانون المختص بشكل الوصية هو القانون الفرنسي. وقضى بأنه في حالة رفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية يثار النزاع فيها حول صحة الوصية الخطية الهولندية، يتعين الرجوع إلى القانون الفرنسي لتكييف الشكل المطلوب، ولما كان القانون يعتبر شكل الوصية سواءً خطياً أو رسمياً مسألة تدخل في نظام شكل التصرفات، فبالتالي يخضع للقانون الفرنسي وهو يقضي بصحة هذه الوصية.

ب رفعت دعوى أمام المحاكم الفرنسية بطلب بطلان زواج أحد اليونانيين لأنه في شكل مدني، في حين أن القانون اليوناني وهو قانون جنسيته يعتبر إشهار الزواج في شكل ديني مسألة موضوعية، ويدخلها في نظام الأحوال الشخصية. بيد أن محكمة النقض الفرنسية قضت بأن القانون الفرنسي وهو القانون المختص بالتكييف، يعتبر مسألة إشهار الزواج في شكل ديني مسألة شكلية لا موضوعية، وبالتالي تخضع لقانون المكان الذي تم فيه الزواج. وقد كان الفقيه الفرنسي بارتان، هو أول من وضع نظرية متكاملة لمشكلة التكييف في فقه القانون الدولي الخاص.

القضايا التي جئها بارتان قضيتي زواج المالطي ووصية الهولندي :

🏛 **تخلص وقائع القضية الأولى،** في أن اثنين من جزيرة مالطة تزوجا في مالطة موطنهما المشترك، ولم يعقدا مشاركة زواج. ثم انتقلا بعد ذلك وأقاما في الجزائر، حيث تملك الزوج بعض العقارات ثم توفي، طالبت الزوجة بحقوقها في عقارات زوجها.

🏛 **عندئذ ثار التساؤل، هل يعتبر حق الزوجة على عقارات زوجها حق ميراث،** فيسري عليه قانون موقع المال وفقاً للقانون الفرنسي الذي يقضي بإخضاع الميراث في العقار لقانون موقعه. **أم أنه يعتبر حقاً متعلقاً بالنظام المالي للزوجين،** وبالتالي يخضع لقانون إرادة المتعاقدين الضمنية وهو قانون موطن الزوجية، أي القانون المالطي.

🏛 قد اعتبرت محكمة استئناف الجزائر أن طلب الزوجة بحقوقها في عقارات زوجها من مسائل الميراث، في حين لو عرض النزاع على المحاكم المالطية لاعتبر متعلقاً بالنظام المالي للزوجين.

🏛 **تخلص وقائع القضية الثانية،** في وفاة هولندي في فرنسا، وكان قد أجرى وصية بخط يده، وعرضت مسألة صحة هذه الوصية على القضاء الفرنسي، وتأسس الطعن في هذه الوصية على أن القانون الهولندي يحرم الوصية الخطية على الهولنديين ولو في الخارج، ويعتبر إجراء الوصية في شكل رسمي مسألة أهلية تتعلق بحماية الموصي. **تأسس دفاع الموصى له، على أن القانون المختص بشكل الوصية هو القانون الفرنسي،** باعتباره القانون المختص بالتكييف. ولما كان القانون يعتبر شكل الوصية سواء خطياً أو رسمياً مسألة تدخل في نظام شكل التصرفات، فبالتالي يخضع للقانون الفرنسي، وهو بالتالي يقضي بصحة هذه الوصية.

اساس نظريه بارتان

🏛 قد رأى بارتان الذي كان له الفضل في بلورة مسألة التكييف وتأصيلها، أن التكييف يخضع لقانون القاضي، فالقاضي يكيف المسألة المعروضة عليه طبقاً لقانونه الوطني، **ويبرر بارتان ذلك بحجتان:**

🏛 **الحجة الأولى** ← أن خضوع التكييف لقانون القاضي نتيجة حتمية لاعتبار قواعد التنازع قواعد وطنية داخلية محضة، حيث تضع كل دولة قواعدها الخاصة بتنازع القوانين كما تشاء. وهذه الحجة مستمدة من **فكرة السيادة.**

🏛 **الحجة الثانية** ← بما أن مرحلة التكييف تسبق مرحلة الإسناد للقانون الأجنبي، فإن القاضي يطبق القانون الأجنبي، إلا إذا تبين من طبيعة النزاع المعروض عليه أنه يخضع للقانون الأجنبي. والقول بما يراه بعض الفقهاء نم إخضاع التكييف للقانون الأجنبي المختص، يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب، **إذ كيف يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي ليعرف منه طبيعة النزاع المعروض عليه، من قبل أن يعرف هل هذا القانون الأجنبي واجب التطبيق أو غير واجب؟**

🏛 **هذا هو رأي بارتان في التكييف.**

🏛 قد أخذ به الفقه الغالب، ولكن على أساس مختلف عن الأساس الذي بنى عليه بارتان نظريته وهو فكرة السيادة. وقد رأى الفقه الحديث، أن تطبيق القانون الأجنبي ليس فيه أي انتقاص من السيادة الوطنية، بل أن المشرع الوطني حينما يسمح بتطبيق القانون الأجنبي في بعض المسائل، فإنما يفعل ذلك لأنه رأى أن القانون هو أقدر القوانين المتزاحمة لحكم العلاقة محل النزاع.

🏛️ **يشير الفقه الحديث إلى حجج أخرى غير فكرة السيادة أهمها :**

- ١- أن التكييف هو في حقيقته لا يعدو أن يكون تفسيراً لقاعدة الإسناد الوطنية، والقاضي لا يلجأ إلى القوانين الأجنبية لتفسير قاعدة الإسناد في قانونه، بل يجب أن يكون التفسير وفقاً لقانون القاضي.
- ٢- أن القاضي حينما يقوم بتكييف العلاقة المطروحة أمامه، لابد أن يتأثر بحكم تكوينه الثقافي والقانوني بالمبادئ الواردة في قانونه.
- ٣- أن عملية التكييف سابقة على أعمال قاعدة الإسناد، من حيث تعاقب الزمن.

ثالثاً: نطاق نظرية بارتان :

🏛️ إن الفقه المؤيد لتطبيق قانون القاضي بالنسبة للتكييف، قد استقر على أن أعمال قانون القاضي قاصر على **التكييف الأولي أو الأساسي**، أي الذي تتحدد به طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين دون التكييفات اللاحقة التي يتطلبها القانون الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد، فهي تخضع لذلك القانون ذاته. ورأى بارتان أن إخضاع التكييفات اللاحقة للقانون الواجب التطبيق قيد على نظريته، وذلك اتفاقاً مع أساس تلك النظرية وهو فكرة السيادة، إذ ما دام تبين اختصاص القانون الأجنبي فلا داعي في الاستمرار في الرجوع إلى قانون القاضي **قد أخذ القضاء برأي بارتان، وشايعته كثير من التشريعات، ومنها القانون المدني المصري.**

🏛️ **ينص في المادة العاشرة على ما يلي :** القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات، عندما يتطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. **قد أدخلت على قاعدة إخضاع التكييف لقانون القاضي، الاستثناءات الآتية :**

- 🏛️ **أولاً:** يخضع تكييف المال، هل هو منقول أو عقار، لقانون موقع المال، دون قانون القاضي، ويبرر هذا الاستثناء، أن كل دولة تهدف إلى حماية ثروتها وخصوصاً العقارية، فالمسألة إذاً متعلقة بالنظام العام، فضلاً عن تطبيق القانون الذي يقع المال في مكانه، أصح وأدق للتمييز بين ما هو منقول وما هو عقار.
- 🏛️ **ثانياً:** يخضع تكييف الفعل وتحديد ما إذا كان يشكل جريمة جنائية أو مدنية، للقانون الذي وقع الفعل في مكانه، ويبرر هذا الاستثناء أنه تقتضيه العدالة وتعلقه كذلك بالنظام العام.
- 🏛️ **ثالثاً:** تخضع المعاهدات، التي تعقد بين دولتين فأكثر، وتتضمن تحديد قانون آخر يخضع له التكييف لهذا القانون، دون قانون القاضي.

رابعاً: إخضاع التكييف للقانون المختص بحكم العلاقة :

🏛️ أنتقد جانب من الفقه ما ذهب إليه بارتان من إخضاع التكييف لقانون القاضي. ورأى إخضاعه للقانون المختص بحكم العلاقة ذاتها، وهو القانون الذي تشير باختصاصه قاعدة الإسناد الوطنية، وذلك استناداً إلى أن لكل قانون تكييفاته، وعلى ذلك، إذا قضت قاعدة الإسناد الوطنية بإخضاع النزاع لقانون أجنبي معين، فإن ذلك القانون هو الذي يجب أن يحكم النزاع برمته. أي بما في ذلك إعطاء الوصف القانوني للمسألة بإعتبارها جزء لا يتجزأ من القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع فإذا لم نأخذ بالوصف القانوني الذي يقرره القانون الواجب التطبيق على النزاع وأخذنا بذلك الوصف الذي يحدده قانون القاضي فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق القانون الأجنبي حيث لا يجب تطبيقه أو عدم تطبيقه في الوقت الذي يجب فيه أن يطبق ففي وصية الهولندي لو أجري القاضي التكييف وفقاً للقانون الفرنسي الذي يعتبر إجراء الوصية في الشكل العرفي الخطي مسألة شكل فإنه يتعطل عندئذ تطبيق القانون الهولندي ولو أجري التكييف وفقاً للقانون الهولندي فكانت النتيجة تطبيق ذلك القانون أي أنه لا يمكن تطبيق القانون الأجنبي قبل الفراغ من عملية التكييف والقول بغير ذلك يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب إذ كيف يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي ليعرف منه طبيعة النزاع المعروض عليه من قبل أن يعرف هل هذا القانون الأجنبي واجب التطبيق أم لا ؟ .

خامساً: إخضاع التكييف للقانون المقارن :

رأي الفقيه الألماني رابل أن الغرض من قواعد الإسناد هو مواجهة المعاملات الدولية، وأنه لذلك يجب أن يتحدد مضمونها تحديداً عالمياً يتفق وحاجة المعاملات الدولية، والسبيل إلى ذلك هو دراسة قوانين الدول المختلفة، ومعرفة الأفكار العالمية واستخلاص مضمون أو مدلول مجرد للفكرة المسندة، وأنه لذلك يجب عدم الاكتفاء بما يقرره قانون معين من تكييفات.

لكن هذا الرأي لم يلق قبولاً لدى القضاء، لما ينطوي عليه من صعوبات عملية، ذلك أنه من العسير على القاضي وهو يحدد طبيعة المسألة وإعطائها الوصف القانوني، أن يرجع إلى قوانين الدول المختلفة.

سادساً: موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف :

تأثرت كثير من التشريعات ومنها التشريع المصري بنظرية بارتان، وأخضعت التكييف لقانون القاضي **←** وقد نصت المادة ١٠ من القانون المدني المصري على أن القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات، عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.

من الواضح، أن التكييف الذي يخضع للقانون المصري، هو التكييف اللازم لتحديد القانون الواجب التطبيق، وبذلك يكون **المشرع المصري قد أخذ بالتفرقة بين التكييف الأساسي أو الأولي، والتكييف الثانوي أو اللاحق.**

المقصود بالقانون المصري **←** الذي يرجع إليه في شأن التكييف وفقاً للمادة العاشرة من القانون المدني هو القانون المصري في جملته بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو الأموال أياً كان مصدر هذه القواعد وكذلك المبادئ العامة في القانون المصري

سابعاً: سكوت المشرع المصري عن النص على الاستثناء الذي قرره بارتان في شأن وصف الأموال:

يرى فريق من الفقه، أنه لا محل للأخذ بهذا الاستثناء، لأن صدور القانون خالياً من النص عليه، يعد دليلاً على عدم رغبة المشرع في الأخذ به، ويرى الفريق الآخر، ضرورة الأخذ بالاستثناء المتعلق بتكييف المال هل هو عقار أم منقول، تأسيساً على أن الأعمال التحضيرية لم تقطع بهجرة، بل على العكس تفتح الباب للتسليم به.

ثامناً: التكييف وقاعدة الإسناد المنفك عليها في معاهدة :

قد ترد قاعدة الإسناد في معاهدة دولية، وعندئذ إذا اتفق في المعاهدة على تكييف معين وجب اتباعه. والاتفاق على التكييف قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً، على أن الأمر يثار عندما يتفق في المعاهدة على قاعدة إسناد، ولا ينص على التكييف اللازم لتطبيقها. ويرى بارتان أنه في هذه الحالة، يتولى القاضي في كل دولة إجراء التكييف على ضوء ما تقضي به النظم القانونية الداخلية في دولته.

ينتقد الأستاذ (نيبواييه) الرأي السابق، لما قد يؤدي إليه من تغيير في أحكام المعاهدة، لأن **الاختلاف في التكييف يترتب على اختلاف نطاق قاعدة الإسناد من دولة إلى أخرى.**

الإسناد ونظرية الإحالة

إذا انتهى القاضي من تكييف المسألة المطروحة عليه، وأدخلها في نظام معين من النظم القانونية التي يحددها قانونه الوطني، انتقل إلى البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة. ويلاحظ اختلاف قواعد التنازع في التشريعات الوطنية، ف**بعض التشريعات تجعل قاعدة التنازع فردية.**

مثال ذلك **←** أن تقول قاعدة الجنسية المصرية: يعتبر مصرياً من توافرت فيه شروط معينة، فهذه قاعدة فردية لا تتعرض إلا لتحديد الجنسية المصرية، أما إذا قالت قاعدة التنازع، الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، فإنها تكون قاعدة مزدوجة، إذ هي تبين أن القانون المصري يطبق على حالة المصريين وعلى أهليتهم، وان الأجنبي يخضع في حالته وأهليته لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.

⚖️ إذا كانت قاعدة التنازع مزدوجة، وجعلت الاختصاص إما للقانون الوطني وإما للقانون الأجنبي، فإنه قد يحدث حينئذ فرضان : تنازع إيجابي أو تنازع سلبي.

الفرض الأول : التنازع الإيجابي

⚖️ يحدث التنازع الإيجابي حينما يقضي كل من القانونين الوطني والأجنبي بحكم العلاقة.
⚖️ **مثال ذلك** → أن يقوم فرنسي مقيم في إنجلترا بتصرف متعلق بحالته وأهليته، فالقانون الفرنسي يقضي باختصاصه بحكم هذا التصرف، لأنه يخضع حالة الشخص وأهليته بقانون جنسيته، وفي ذات الوقت يقضي القانون الإنجليزي باختصاصه، بحكم هذا التصرف، لأنه يخضع حالة الشخص وأهليته لقانون موطنه.

⚖️ **أذن فهناك تنازع إيجابي بين القانونين فأيهما يعمل؟** من المتفق عليه فقهاً وقضاءً، أن على كل قاض أن يطبق قانونه الوطني احتراماً لمبدأ سيادة القانون على إقليم الدولة، فعلى القاضي الفرنسي في هذا المثال أن يطبق قانونه إذا عرض عليه النزاع بصرف النظر عن القانون الإنجليزي.

الفرض الثاني : التنازع السلبي

⚖️ يحدث التنازع السلبي، حينما يتخلى كل من القانونين عن اختصاصه بحكم المسألة.
⚖️ **مثال ذلك** → أن يقوم انجليزي مقيم بفرنسا بتصرف متعلق بأهليته، ففي هذا المثال يقضي القانون الفرنسي بإخضاع هذا التصرف لقانون الموطن وهو القانون الفرنسي. فماذا يكون الحل في مثل ذلك؟

س هـ : عرف المقصود بالإحالة وصورها وما هو موقف المشرع المصري منها ؟

نظرية الإحالة

ماهية الإحالة :

⚖️ تعرض مسألة الإحالة بصدد التنازع السلبي فكل دولة قواعد قانونية داخلية تطبق علي رعاياها وقواعد أخرى خاصة بتنازع القوانين وداخلية في القانون الدولي الخاص تطبق علي العلاقات التي تشتمل علي عنصر أجنبي فإذا وجب تطبيق قانون أجنبي فأي قانون يجب الرجوع اليه فإذا تم تطبيق القانون الداخلي نكون من انصار رفض الإحالة.

⚖️ **يمكن تعريف الإحالة بأنها:** تلك النظرية التي تقضي بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق على العلاقة، بمقتضى قواعد التنازع الوطنية. ولم تظهر مشكلة الإحالة إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بمناسبة القضية المشهورة التي عرضت على القضاء الفرنسي سنة ١٨٧٨ وهي قضية فورجو وتتلخص وقائعها. في أن فورجو هذا كان ولداً غير شرعي، ونزحت به أمه وهو طفل في الخامسة من العمر إلى فرنسا وأقام هناك إقامة فعلية، دون أن يتخذا لهما موطناً قانونياً في فرنسا، وعندما شب فورجو، تزوج من فرنسية ثرية، ماتت وتركت له ثروة منقولة طائلة، وفي الثامنة والستين من العمر توفي فورجو بمدينة (بوردو) تاركاً هذه الثروة المنقولة دون أن يترك ورثة مباشرين، أي دون أب أو أم أو أخوة.

⚖️ لما كان القانون الفرنسي لا يعطي الحق في ميراث الولد غير الشرعي إلا لأبوه وأخوته فقط، فقد استولت مصلحة الأموال الفرنسية على هذه الثروة باعتبارها تركة بلا وارث. فطالب الحواشي من أقارب أمه بالميراث، فقضت محكمة استئناف (بوردو) برفض طلبهم مستندة إلى أن فورجو كان متوطناً بفرنسا، وبالتالي يجب أن يطبق على ميراث ثروته المنقولة القانون الفرنسي، وهو يقضي بحرمان غير الأبوين والأخوة للولد غير الشرعي من ميراثه. ثم توالى أحكام القضاء الفرنسي على هذا النحو، آخذة بالإحالة، واستمر قضاء هذه المحكمة مضطرباً في هذا الاتجاه حتى الآن.

🏛️ **في مصر كما في القوانين العربية**، فلم يؤخذ بالإحالة، وقد نصت المادة ٢٧ من القانون المدني المصري على أنه إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص

🏛️ نخلص من ذلك، إلى أن الإحالة هي نظرية تقول بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في القانون الأجنبي الواجب التطبيق

صور الإحالة

للإحالة صورتان:

- أ. **إحالة من الدرجة الأولى** ← حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون القاضي.
مثال ذلك ← أن يقوم انجليزي مقيم بفرنسا بتصرف متعلق بأهليته، فيطبق عليه القانون الفرنسي قانون جنسيته وهو القانون الإنجليزي، ولكن قواعد التنازع في القانون الإنجليزي تحيل إلى قانون الموطن وهو القانون الفرنسي، وتسمى هذه الصورة الرجوع.
- ب. **إحالة من الدرجة الثانية** ← حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون ثالث. كما لو كان هذا الإنجليزي متخذاً له موطناً في إيطاليا، ورفع الأمر إلى القاضي الفرنسي، فإنه لو قبل إحالة القانون الإنجليزي إلى القانون الإيطالي، فسوف يطبق القانون الإيطالي. وقد تعدد الإحالة في هذه الصورة، إذ قد يحيل القانون الإيطالي إلى قانون رابع.

موقف الفقه من الإحالة:

🏛️ **لقد انقسم الفقه بصدد الإحالة إلى مؤيدين ومعارضين. فأما الفقهاء الذين يؤيدون الإحالة، فإنهم يستندون إلى الحجج الآتية حجج المؤيدين للأخذ بالإحالة.**

- 🏛️ **أولاً:** متى كان القانون الأجنبي واجب التطبيق، فيجب أن يرجع إليه باعتباره كلا لا يتجزأ، سواء في ذلك قواعده الداخلية أو قواعد التنازع فيه ولا يسوغ الأخذ بقواعده الداخلية دون قواعد التنازع فيه إذ يكون في ذلك تمييز بين قواعده وتجزئة له لا مبرر لها.
- 🏛️ **ثانياً:** من غير المستساغ أن يكون القاضي الذي يعرض عليه النزاع (ملك أكثر من الملك). فإذا كان هذا القانون يتخلى عن اختصاصه لقانون آخر، سواء قانون القاضي أو قانوناً آخر غيره، بحكم قواعد التنازع فيه، فكيف يطبق القاضي المعروض عليه النزاع قواعد هذا القانون الأجنبي الداخلية رغماً عنه؟
- 🏛️ **ثالثاً:** في الأخذ بالإحالة تسهيل وتعمير للحلول في القضايا، إذ لو أن كل قاض أخذ بالإحالة فإن حكمة سوف يتمتع بحجية الشيء المقضي به، أمام جميع محاكم الدول التي تأخذ بالإحالة.
- 🏛️ **رابعاً:** في الأخذ بالإحالة تيسير للكثير من المشاكل، في حالة ما إذا كان الأمر متعلقاً ببلد تتعدد فيه الشرائع، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. فلو فرضنا أن أمريكياً متوطناً بفرنسا قام بتصرف يتعلق بحالته الشخصية، وعرض نزاع بشأنه أمام القضاء الفرنسي، فلو أخذ القاضي الفرنسي بالإحالة، فسوف يقبل إحالة القانون الدولي الخاص الأمريكي على قانون الموطن.
- 🏛️ لو لم يأخذ بالإحالة مضطر لكي يطبق على هذا الأمريكي قانون حالته الشخصية، فعليه أن يرجع إلى قوانين الولايات الأمريكية الشخصية، وهي ثلاث وخمسون ولاية، لكل واحدة منها قانون أحوال شخصية مستقل.

معارضو الإحالة فيقولون ما يلي:

- 🏛️ **أولاً:** حين تشير قاعدة التنازع في قانون القاضي بتطبيق قانون أجنبي، فإنما هي تريد بذلك تطبيق قواعده الداخلية، دون قواعد التنازع فيه، لأن هذه القواعد لم توضع إلا للعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، فكيف يرجع إليها بصدد علاقات وطني الدولة نفسها؟

ثانياً: حين تقضي قاعدة التنازع في قانون القاضي بتطبيق القانون الأجنبي، ويرجع إلى قواعد التنازع في هذا القانون، فتحيله على قانونه هو بينما قانونه يحيله على القانون الأجنبي، فإن الأمر يصير كما لو كانت هناك (لعبة تنس)، ففي هذه اللعبة كلما تلقى اللاعب الكرة ردها بمضربه إلى الآخر، ولذلك تسمى هذه الحجة حجة مضرب التنس.

ثالثاً: قد تكون قواعد التنازع في القانون الأجنبي الواجب التطبيق نصوصاً دستورية، كما هي الحال في البرازيل، فإذا رجع القاضي إلى هذه القواعد دون أن يرجع إلى القواعد الداخلية، فإنه يكون قد عمل بمقتضى قاعدة دستورية أجنبية في بلده، مع أن ذلك يتضمن الخضوع لسيادة أجنبية.

رابعاً: قد يؤدي الأخذ بالإحالة إلى الإجحاف بحقوق الأفراد، وتطبيق نظم قانونية عليهم ليسوا خاضعين لها في بلادهم.

خامساً: يدعى أنصار الإحالة أن في الأخذ بها تسهياً لتنفيذ الأحكام، خصوصاً في بلد القانون المحيل.

هذه حجة واهية، إذ لو فرضنا أن المسألة هي مسألة طلاق انجليزي متوطن في فرنسا عرضت على القاضي الفرنسي، فإن هذا القاضي سوف يرجع في حكم هذه المسألة إلى قانون جنسية الإنجليزي، وهو سوف يحيله على قانون الموطن، فيطبق على هذه المسألة قواعد القانون الفرنسي. بينما لو عرض أمر هذا الإنجليزي على القاضي الإنجليزي، فإنه سوف يرجع إلى قانون موطن هذا الشخص، وهو القانون الفرنسي، فتحيله قاعدة التنازع في القانون الفرنسي إلى القانون الإنجليزي باعتباره قانون الجنسية، فيقضي طبقاً لقواعد القانون الإنجليزي.

إذاً فالقول بأن القاضي المحال على قانونه، سوف يحكم كما لو كان قاضي القانون المحيل هو الذي يحكم، قول غير صحيح. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما يتم تنفيذ الحكم في ذات البلد الذي صدر فيه، أو في بلد آخر غير البلد الذي أحال قانونه، فليس صحيحاً أن في الإحالة تسهياً لتنفيذ الأحكام.

محاولات فقهية أخرى، تؤدي إلى ذات النتيجة المترتبة على الأخذ بفكرة الإحالة

١- **وجود قاعدة تنازع احتياطية** ← اقترح الفقيه "لوربوريجو" بدلاً من الإحالة، أن يقال أن قواعد التنازع في كل دولة تتضمن قاعدة احتياطية إلى جانب القاعدة الأصلية وإذا طبق القاضي هذه القاعدة الاحتياطية فإنه يكون مؤتمراً بأمر مشرعه بذلك يمكن تفادي ما وجه إلى الإحالة من الاعتراض بأنها تؤدي إلى أن ياتمر القاضي بأمر مشرع أجنبي وبقتصر هذا الفقيه إقتراحه هذا علي مسائل الأهلية والحالة والميراث في المنقول ويبدو أنه لا يري تطبيقه في نطاق الإتفاقات التعاقدية ولا فيما يتعلق بشكل التصرفات.

٢- **مبدأ إقليمية القوانين** ← يجب الرجوع إلى الأصل وهو إقليمية القوانين، هذا المبدأ الذي يقضي بأن الأصل هو أن يطبق كل بلد قانونه داخل إقليمه وإستثناء من هذا الأصل قد يضطر في بعض الحالات إلى الأخذ بمبدأ إمتداد القوانين الأجنبية إلى إقليمه فيقبل تطبيق القانون الأجنبي علي سبيل التضحية ولمصلحة التعامل القانوني بين الدول فإذا لم يقبل القانون الأجنبي إمتداده إلى إقليم البلد الذي يسمح له بهذا الأمتداد علي سبيل التضحية ساغ عندئذ رجوع القاضي المرفوع أمامه النزاع إلى قانونه الوطني أي ساغ العدول عن الإستثناء والرجوع إلى الأصل وهو الإقليمية.

٣- **نظرية المحكمة الأجنبية** ← وقد قال بهذه النظرية فريق من الفقه الإنجليزي، وهي تعني أنه إذا عرض على القاضي الوطني نزاع يشتمل على عنصر أجنبي. وجب على القاضي أن يفصل في النزاع، كما يفصل فيه القاضي في الدولة الأجنبية. أي يطبق القانون الذي كان سيطبقه القاضي الأجنبي. وبمعني اخر يضع القاضي الوطني نفسه موضع القاضي في هذه الدولة الأجنبية ويفصل في النزاع كما يفصل فيه القاضي الأجنبي أي يطبق القانون الذي كان سيطبقه القاضي الأجنبي سواء كان يأخذ بالإحالة أو لا يأخذ بها.

🏛 يتصور انصار هذه النظرية أنهم تفادوا الوقوع في الحلقة المفرغة التي تؤدي إليها الإحالة أو "لعبة التنس" وهذه النظرية وإن كانت تستجيب لمقتضيات التعاون بين الدول في مجال المنازعات ذات الطابع الدولي إلا أنه يؤخذ عليها إفتراضها تجرد القاضي المعروض عليه النزاع من صفته كقاضي وطني وتقلده القضاء مؤقتاً في الدول الأجنبية التي يخضع النزاع لقانونها وقد اخذ القضاء الإنجليزي الحديث بنظرية الإحالة الكلية التي يسميها او نظرية المحكمة الأجنبية **وطبقاً لهذه النظرية** علي القاضي الانجليزي ان يفصل في النزاع المشتمل علي عنصر اجني طبقاً للحل الذي كان يمكن ان ينتهي إليه القاضي الأجنبي الذي تحيل علي قانونه قاعدة التنازع الإنجليزية .

موقف المشرع المصري من الإحالة - رفض الأخذ بها:

🏛 رفض المشرع المصري صراحة وبصورة مطلقة الأخذ بفكرة الإحالة، فنص في المادة ٢٧ من القانون المدني على أنه إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، **فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.**

🏛 يتضح من هذا النص أن المشرع قد اخذ موقفاً حاسماً من نظرية الإحالة برفضه الأخذ بها وإلزام القاضي الوطني بالإقتصار علي تطبيق القواعد الداخلية في القانون الأجنبي دون تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص ذلك ان قاعدة الإسناد حين تجعل الإختصاص التشريعي لقانون معين تصدر عن إعتبارات خاصة وفي قبول الإحالة أياً كان نطاقها تفويتاً لهذه الاعتبارات ونقض لحقيقة الحكم المقرر في تلك القاعدة .

🏛 قد بارك الفقه المصري الغالب بحق موقف المشرع برفض الإحالة تلافياً للوقوع في الحلقة المفرغة ولأن الإحالة تفتقر إلي أساس نظري سليم .

🏛 انتقد الجانب الآخر من الفقه الحكم الوارد برفض الإحالة ورأوا ان قبول الإحالة إلي قانون القاضي هي إستكمالاً لسيادة القانون المصري وتمشياً مع الفقه الحديث الذي يتجه نحو الحد من إمتداد القانون والنظر إلي السيادة الإقليمية بإعتبارها الأصل في سلطان القانون وليس الرجوع إلي القانون المصري إنصياً لقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي بل هو نتيجة طبيعية لرفض القانون الأجنبي الأختصاص التشريعي الذي يعقده له القانون المصري .

🏛 قد حاول جانب اخر قبول الإحالة من الدرجة الأولى علي اساس أن وظيفة قاعدالإسناد هي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونية المختلفة والوصول إلي أكثر الحلول تلبية لمقتضيات التجارة الدولية .

الدراسة التطبيقية لتنازع القوانين

تطبيق القانون الأجنبي باعتباره قانوناً شخصياً خاصاً بالأحوال الشخصية

تحديد نطاق الأحوال الشخصية:

🏛 تشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم، أو المتعلقة بنظام الأسرة، كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين، والطلاق والتطليق والتفريق، والبنوة، والإقرار بالأبوة وإنكارها، والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، والولاية والوصاية والقوامة والحجر، والإذن بالإدارة، واعتبار المفقود ميتاً، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا.

الأحوال الشخصية بين قانون الجنسية وقانون الموطن

🏛 تختلف الدول فيما بينهما في إناطة الأحوال الشخصية، فبعضها ينيطها بقانون الجنسية، وبعضها ينيطها بقانون الموطن، ولكل وجهة نظر يبررها حجج قوية أنصار قانون الجنسية.

أولاً: الدول التي تنيط الأحوال الشخصية بقانون الجنسية، فإنها تبرر وجهة نظرها بالحجج الآتية :

١. ضرورة استقرار الأحوال الشخصية وثباتها فيما أن الجنسية ثابتة مستقرة عسيرة التغيير، فإن القانون الذي يرتبط بها يكون أثبت وأصلح من قانون الموطن لحكم الأحوال الشخصية.
 ٢. تضع الدولة قوانين الأحوال الشخصية لرعاياها دون سواهم من الأجانب ويجب أن تتبع هذه القوانين رعاياها أينما أنتقلوا وهي لا تتبعهم خارج الدولة إلا إذا أرتبطت بجنسيتهم.
 ٣. الأخذ بقانون الجنسية، يغرس في نفوس رعايا الدولة التي يتبعونها بجنسيتهم الشعور بقوميتهم.
 ٤. كل دولة تهتم برعاياها في الخارج وتعني بحماية حقوقهم بواسطة سفاراتها وقنصلياتها، ومن حق هؤلاء الرعايا الذين يحملون معهم قانون جنسيتهم، أن يرجعوا في كل تصرفاتهم إلى سفارات دولتهم وقنصلياتهم لتدافع عن حقوقهم وتحميهم.
- قد اخذ القانون المدني الفرنسي العتيق بقانون الجنسية كما اخذ به مشروع القانون المدني الجديد وأخذت به اغلب الدول الأوروبية والبلاد العربية ومن اظهر انصار قانون الجنسية من الفقهاء مانشيبي في ايطاليا ريبه وباتيغول في فرنسا .

ثانياً: أنصار قانون الموطن، فيستندون إلى الحجج الآتية:

١. من اليسير توحيد موطن الأسرة إذا اختلفت جنسية الزوجين ولكن من العسير توحيد جنسية الأسرة إذ أن موطن الزوجة والأولاد القصر هو موطن الزوج والأب في حين أن جنسيته قد لا تكون هي جنسيتهم.
٢. قانون الموطن هو الواجب التطبيق، حينما يكون هناك شخص بلا جنسية.
٣. قانون الموطن أصلح من قانون الجنسية بالنسبة إلى المهاجرين الذين توطنوا في إقليم آخر إذ يكون من مصلحتهم أن يسري عليهم قانون الموطن الذي يعرفونه دون قانون جنسيتهم وربما كانوا يجهلونه ببعدهم عن إقليم دولتهم ثم أن من شأن سريان قانون الموطن علي المهاجرين أن يسهل اندماجهم في رعايا الدولة وإلحاقهم بمواطنيها بدلاً من أن يظلوا أجنباً عنها.
٤. بالنسبة إلى المواطنين خير لهم أن يتعاملون مع الأجانب المقيمين معهم في إقليمهم على أساس قانون الموطن الذي هو معروف لهم.
٥. من مصلحة القاضي أن يجري حكم قانونه الذي يعرفه حق المعرفة، بدلاً من أن يبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق.
٦. لو طبق علي كل أجنبي قانون جنسيته في بلد يكثر فيه الأجانب مثل الولايات المتحدة الأمريكية لضاق مجال تطبيق القانون الوطني إلي حد كبير.
٧. الشخص يرتبط بموطنه الذي به مصالحه أكثر مما يرتبط بجنسيته إذ أنه ربما قضي حياته كلها في موطن بعيد عن إقليم دولته.

موقفنا من القانونين :

- الواقع، هو أن اختيار قانون الجنسية أو قانون الموطن **مسألة نسبية**، يتوقف حلها على ظروف كل دولة، ولا يمكن مطلقاً أن يعمم الحكم كقاعدة عامة تسري على جميع الدول. فمما لاشك فيه أنه إذا كانت الدولة كثيفة السكان وتصدر رعاياها إلي الخارج بنسبة أعلي بكثير جداً من الأجانب الذين يهاجرون إليها مثل ألمانيا وبولونيا وإيطاليا فإنه يكون من الخير لها أن تسند الأحوال الشخصية لقانون الجنسية ليظل رعاياها مرتبطين بها وهم في الخارج إرتباطاً قانونياً ويقوموا بالدعاية لها وبنشر ثقافتها ثم يدفعهم الحنين إلي الوطن في نهاية المطاف إلي أن يعودوا إلي وطنهم بما جمعوا من ثروات ولا يكون هناك خطر علي قانون الدولة الإقليمي إذا طبق علي الأجانب قانون جنسيتهم ما داموا قلة ضئيلة .
- علي العكس من ذلك كلما كانت الدولة فقيرة في عدد سكانها محتاجة إلي إستيراد اليد العاملة من الخارج ومحتاجة إلي العنصر الفني من الخارج كما الحال في البلاد الغربية مثل فرنسا التي تعتبر فقيرة في عدد سكانها وفي عدد العمال بها فيكون من مصلحتها أن تسند الأحوال الشخصية إلي قانون الموطن لا سيما إذا كانت لا تصدر إلي الخارج من رعاياها إلا النذر اليسير .

يقترح الفقيه الفرنسي نبواييه وهو من أنصار قانون الموطن أن تفرق دولة كفرنسا بين رعاياها والأجانب المقيمين فيها بإستمرار والأجانب الموجودين فيها بصفة مؤقتة ويرى أن تسند الأحوال الشخصية لرعاياها إلي قانون جنسيتها وأن تسند الأحوال الشخصية للأجانب المقيمين بها بصفة دائمة إلي قانون الموطن وأن تسند الأحوال الشخصية للأجانب الموجودين بها بصفة مؤقتة كالطلبة والسائحين ورجال الأعمال إلي قانون جنسيتهم .

يرى الفقيه الفرنسي باتيفول وهو من مؤيدي قانون الجنسية أنه يتعين التوفيق بين القوانين ولا يجب الأخذ بأحدهما بصفة مطلقة ولقد أخذت التشريعات الحديثة تتجه مثل هذا الإتجاه .

موقف القانون المصري من القوانين :

موقف القانون المدني المصري من ذلك، فقد نص في المادة ١/١ على ما يلي: الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وهكذا **احاط القانون المدني المصري الأحوال الشخصية بقانون الجنسية.**

نظيف قانون الجنسية في حالة إنعدامها ونعدها

يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه، في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية. وإذا كان النزاع متعلقاً بحالة شخص متعدد الجنسيات أو بأهليته، فإما أن تكون الجنسية المصرية هي إحدى الجنسيات المتنازعة أو لا تكون، ففي الحالة الأولى يطبق القاضي المصري قانون الأحوال الشخصية المصري، وبصرف النظر عن قانون الجنسية أو الجنسيات الأخرى. أما في الحالة الثانية، أي في حالة تنازع جنسيات أجنبية ليست الجنسية المصرية من بينها، فإن القاضي المصري هو الذي يعين القانون الواجب التطبيق.

الجنسية الفعلية:

تلك الجنسية التي يرتبط بها الشخص أكثر من سواها أو أنها تلك الجنسية التي يظهر من ظروف الواقع وملابسات الحال أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها
جنسية تتفق مع الواقع وتقوم علي صلة أو رابطة فعلية بين الشخص واحدي الدول التي تتنازع جنسياتهم لحكم النزاع

مؤشراتها ← ويتم استظهارها من خلال استعانة القاضي المطروح امامه النزاع ببعض القرائن والمؤشرات التي تكشف عنها **مثل** موطن الشخص محل اقامته ومقر مصالحه وروابطه الاسرية والعائلية واشتراكه في الحياة العامة في دولة دون اخري الي غير ذلك من المؤشرات التي تكشف عن رغبة الشخص وتعلقه بالارتباط بدولة معينة من الدول التي يحمل جنسيتها دون سواها وهي مسألة واقع تخضع لتقدير القاضي المطروح امامه النزاع وتفلت بالتالي من رقابة محكمة النقض مادام استخلاصه لها كان مبررا سائغا ببيانه المؤشرات التي اعتمد عليها في هذا الاستخلاص

تحديد قانون الجنسية لدولة نثعد فيها الشرائع :

إذاً وجب تطبيق قانون أجنبي على نزاع متعلق بالأحوال الشخصية، وكان البلد الذي يجب تطبيق قانونه من البلاد التي تتعدد فيها الشرائع الداخلية سواء إقليمياً أو طائفيًا فإن **قواعد التنازع الداخلي بين الشرائع هي التي تتولى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق من بين هذه الشرائع المتعددة** وتسمى هذه الحالة "الإحالة الضرورية أو الداخلية" ويسميا بيه بالتفويض .

لا تعتبر هذه إحالة وذلك لأن الإحالة تقتضي تخلي القانون الواجب التطبيق عن حكم العلاقة القانونية التي تخضع له وإحالة الحكم إلي قانون دولة اخري بينما في الاحالة الداخلية التي نحن بصدها لا يتخلي القانون الأجنبي الواجب التطبيق عن حكم العلاقة وانما هو يعين الشريعة التي يجب تطبيقها من بين الشرائع المتعددة في دولته ويجري هذا التعيين طبقاً لقواعد التنازع الداخلي بين الشرائع .

إذا لم يتعرض القانون الداخلي لهذا التنازع ولم يبين أية شريعة يجب تطبيقها ففي هذه الحالة يري بعض الفقهاء الرجوع إلى **قانون عاصمة الدولة** وتطبيقه بينما يري البعض الآخر الرجوع إلى **قانون الولاية أو المقاطعة** التي يرتبط بها الشخص ذو الشأن في الواقع ولكن هذا الرأي لا يحل الإشكال إذا كان التعدد طائفيًا ولذلك فالرأي الذي ساد لدي أغلبية الفقه أخيراً هو ان **(يعمل بقانون الموطن)** بدلاً من قانون الجنسية وهو مبرر إضافي لتفضيل قانون الموطن .

الموضوعات التي تندرج في نطاق الأحوال الشخصية

المقصود بالأحوال الشخصية ← هو مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية، ككون الإنسان ذكراً أو أنثى، وكون زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنونه.

في مصر، يعتبر من مواد الأحوال الشخصية، الحالة والأهلية العامة وحماية ناقص الأهلية، والزواج، والمشاركات المالية التي تصحبه، والطلاق والتطليق والانفصال الجسماني، والبنوة والتبني وإثبات النسب، والولاية والنفقة بين الأقارب، والميراث والوصية.

أولاً: الحالة :

١- حالة الشخص الطبيعي:

مجموع الصفات التي تحدد مركزه من أسرته، وتسمى الحالة المدنية، وتشمل مجموع صفاته الطبيعية ككونه ذكراً أو أنثى، رشيداً أو قاصراً، زوجاً أو أعزب أو أرمل أباً أو ابناً.

قد نصت المادة ١١ من القانون المدني المصري، على أن : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها

قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

٢- حالة الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري حالة سياسية وحالة قانونية، ويقصد بالحالة السياسية، تبعية الشخص الاعتباري لدولة معينة، وقد جرى الفقه والقضاء والمشرع في بعض الدول على وصف الرابطة السياسية بالجنسية. أما الحالة القانونية أو النظام القانوني للشخص الاعتباري، فيقصد به كيفية تكوينه وإدارته وتصرفاته وانقضائه. وقد تناول المشرع المصري الحالة القانونية للشخص الاعتباري في المادة ١١ بقولها أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

على ذلك، **فتخضع حالة الشخص الاعتباري لقانون الدولة التي يتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي**، غير أنه إذا كان مركز إدارة الشخص الاعتباري الرئيسي الفعلي في بلد أجنبي، ومركز نشاطه الرئيس في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري، دون قانون البلد الذي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي الفعلي.

حكم مقرر لصالح القانون المصري ويراد بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي مركز الإدارة الحقيقي وليس الافتراضي ويتعرف القضاء علي مركز الإدارة الرئيسي من ظروف الحال ومن أهم العناصر التي يستعين بها في تقديره مكان إجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكاتب الإدارة ويراد بمركز النشاط الرئيسي مركز الإستغلال .

ثانياً: الأهلية:

المراد بالأهلية هنا أهلية الأداء لا أهلية الوجوب ← ويخضع تكييف الأهلية لقانون القاضي طبقاً للقاعدة العامة في التكييف، أما قانون الجنسية، فهو الذي يحدد مدى أهلية الشخص، ومتى يبلغ سن الرشد، وما هي التصرفات التي يعتبر أهلاً للقيام بها وتلك التي لا يستطيع القيام بها، وإذا كان سريان **قانون الجنسية هو الأصل في القانون المصري** طبقاً لنص المادة ١/١١ التي نصت على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. فإن هذا النص **قد أدخل على هذا الأصل استثناءً**، نصت عليه العبارة الأخيرة، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته، فطبقاً لهذا النص المستثنى من الأصل، وهو خضوع الأهلية لقانون جنسية الشخص، **وتخضع الأهلية لقانون القاضي. إذا توافرت الشروط الآتية:**

- ١- أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي يدخل في نطاق التصرفات المالية، فإذا كان التصرف يدخل نطاق الأحوال الشخصية فلا يطبق هذا النص الاستثنائي.
- ٢- وأن يتم هذا التصرف في مصر وينتج آثار فيها.
- ٣- أن يكون الأجنبي الذي قام بهذا التصرف كامل الأهلية طبقاً لقانون جنسيته.
- ٤- وأن يكون نقص أهلية الأجنبي طبقاً لقانون جنسيته، يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف المتعاقد معه تبينه وعلي ذلك فإذا كان سبب نقص أهليته ظاهراً لا خفاء فيه كما لو كان صبيّاً صغيراً أو كان مجنوناً مطبقاً فلا يعمل بهذا النص ..

قد يعترض على هذا الشرط بقاعدة لا عذر بجهل القانون فكيف يعذر المتعاقد مع الأجنبي بجهله لقانون هذا الأجنبي؟ لكن يرد على هذا الاعتراض، بأن هذه القاعدة تقتصر على الجهل بالقانون الوطني؟ بينما الجهل بالقانون الأجنبي عذر مقبول.

قد اختلف الفقه حول ما إذا كان هذا الحكم الاستثنائي موضوعاً لحماية الأشخاص الوطنيين فقط، أو هو موضوع لحماية المصلحة الوطنية بصرف النظر عن جنسية العاقد؟ فإذا أخذنا بالرأي الأول، استلزم الأمر شرطاً خامساً، يقضي بأن يكون المتعاقد مع الأجنبي مصرياً. أما إذا أخذنا بالرأي الثاني، فلا محل لاشتراط الشرط الخامس. بيني الفقهاء الفرنسيون هذا الاستثناء على أساس المصلحة الوطنية التي تقضي باستبعاد القانون الأجنبي إذا كان تطبيقه ضاراً بالمصلحة الوطنية، غير أن بعض الفقهاء في فرنسا يرون أن استبعاد تطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة يرجع إلى فكرة النظام العام. والواقع، هو أنه لا حاجة بنا إلى تلمس أساس آخر لهذا الاستثناء ما دام الجهل بالقانون الأجنبي عذراً مقبولاً، فالجهل بالقانون الأجنبي أساس صالح لهذا الاستثناء.

١- الأهلية اللازمة للتجارة:

حدد المشرع في المادة (١١) من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م سناً خاصة للاشتغال بالتجارة وذلك لما يتطلبه الاشتغال بالتجارة من حيطة وحذر بسبب المخاطر التي تحيط بهذه الأعمال فنص على انه يكون اهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان او اجنبياً

أ- من بلغت سنة احدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسية يعتبره قاصراً في هذه السن

ب- من اكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي اذن من المحكمة المصرية المختصة

لايجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ان يزاوّل التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن اويجيز له الاتجار

- تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات.
- كما ان المادة (٥٧) من الرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص باحكام الولاية علي المال قد نصت علي انه لايجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية او الوصاية ان يتجر الا اذا بلغ الثامنة عشر من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذا مطلقاً او مقيداً
- المشرع قد حدد سنّاً خاصة للاشتغال بالتجارة بالنسبة للمصريين والأجانب، فبالنسبة للمصريين جعلها ٢١ سنة، وهي سن الرشد بصفة عامة.
- بالنسبة للقاصر** لا يتجر إلا إذا بلغ ١٨ سنة وبإذن من المحكمة. **بالنسبة للأجانب**، فإنه إذا كان بالغاً الثامنة عشرة سنة، فإما أن يكون راشد وفقاً لقانونه، وفي هذه الحالة يجوز له الاشتغال بالتجارة بعد إذن المحكمة الابتدائية، وأما إذا كان قاصراً وفقاً لقانونه، فإنه لا يجوز له الاشتغال بالتجارة، إلا إذا كان قانونه يجيز له ذلك.
- بالنسبة لأهلية النساء للتجارة تكون أهلية النساء للتجارة علي حسب قانون أحوالهن الشخصية " وعلي مقتضي ذلك يرجع إلي قانون جنسية المرأة الأجنبية لمعرفة مدي أهليتها للإشتغال بالتجارة .

٢- الوضعية بالنسبة لعديم الأهلية وما يستلزمه من حماية :

- عديم الأهلية في حاجة إلى حماية في نفسه وفي ماله، وحمايته في نفسه تعتبر من روابط الأسرة وليس هنا محل دراستها، وأما المسائل المتعلقة بحمايته في ماله، فقد استقر الفقه والقضاء في مصر، على اعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية.

٣- إخضاع حماية عديم الأهلية لقانون جنسيته :

- نصت المادة ١٦ من القانون المدني، على أن يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة غيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته، ومفاد ذلك، أن الاختصاص بحماية عديم الأهلية ومن في حكمه، يسند إلى قانون جنسيته. والمشرع يقرر قاعدة الإسناد بالنسبة لاختيار الوصي أو القيم، ويوجب اتباع قانون بلد عديم الأهلية أما بالنسبة للإجراءات فإنها تخضع للقانون المصري .

ثالثاً الزواج :

- لعل الزواج هو أفصح العلاقات القانونية مجالاً لتنازع القوانين ذلك أن النظم القانونية تختلف في نظرتها إلي هذه الرابطة إختلافاً كبيراً فبعضها تعتبر هذه الرابطة في بعض النظم رابطة دينية محضة إذا بها تعتبر في بعض النظم الأخرى مدنية بحتة وبينما الدول الإسلامية تبيح تعدد هذه الرابطة وتسمح بإنحلالها بإرادة منفردة إذا بالدول المسيحية تحرم تعددها وتعتبر التعدد جريمة وبعضها يعتبرها رابطة أبدية غير قابلة للإنحلال بينما البعض الآخر يبيح إنحلالها ولكن لأسباب محددة بل أن بعض الدول تعتبرها رابطة مؤقتة مثل الإتحاد السوفيتي .

١- تحديد مضمون فكرة الزواج :

- الزواج** ← عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، واستمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع، ويحدد لكل منهما ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
- متي كان ما سلف هو معنى فكرة الزواج بصفة عامة وانها في الشريعة الإسلامية يمكن ان تتعدد وتنحل فإنه يتعين علي القاضي الوطني المصري وهو بصدد تكييف رابطة الزواج ان ينظر اليها بمفهوم اوسع مما هو وارد في قانونه (الشريعة الإسلامية) اي يجب عليه ان ينظر إليها علي انها رابطة تفيد حل استمتاع كل من الزوجين علي الوجه المشروع دون تقييد بما قرره الشريعة الإسلامية من جواز التعدد والإنحلال وبهذا النظر يستطيع القاضي ان يدخل في فكرة الزواج كافة النظم التي تسمي زواجا ولا تتعدد فيها الرابطة ولا تنحل بإرادة أحد الطرفين .

٢- الخطبة:

لقد جرت العادة على أن تبدأ إجراءات الزواج بالخطبة، وهي وعد يبدي فيه كل طرف استعداداه للزواج من الآخر، فإذا وصلت الخطبة إلى مرحلة الوعد، فلا شك في أنها تعتبر كمقدمة للزواج وتدخل في نطاق الأحوال الشخصية.

إذا فسخت الخطبة وترتبت على فسخها المسؤولية التقصيرية، فإن هذه المسؤولية تخضع لقانون المحل الذي حصلت فيه.

س٧: وضع القانون الواجب التطبيق بشأن الشروط الموضوعية للزواج؟

٣- الشروط الموضوعية لانعقاد الزواج:

الشروط الموضوعية ← الرضاء والأهلية، وموافقة الأولياء على النفس إن لزم الأمر، وخلو الزوجين من الموانع الشرعية. يرجع في تكييف ما هو موضوعي من شرط الزواج لقانون القاضي طبقاً للقاعدة العامة.

قد نصت المادة ١٢ من القانون المدني المصري على أنه **يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين فقانون جنسية كل من الزوجين هو الذي يسري على زواجهما**، ويعتد بهذا القانون وقت إبرام الزواج فقط، فإذا تغيرت جنسية أحدهما بعد ذلك فلا يتأثر عقد الزواج بهذا التغيير. وليس في إخضاع شروط الزواج الموضوعية لقانون الجنسية أية صعوبة إذا كان الزوجان متفقان جنسية.

يرى بعض الفقهاء وجوب التطبيق الجامع، باعتبار أن كلا من القانونين وضع شروطه لحماية رابطة الزوجية التي لا تتحقق إلا بين الزوجين، غير أن هذا الرأي عسير التحقيق عملاً، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تطبيق القانون الأكثر تشدداً، ولذلك فالرأي السائد، والذي سار عليه القضاء هو التطبيق الموزع، فيكفي أن تتوافر في الزوج الشروط الموضوعية التي يقتضيها قانون جنسيته، وأن تتوافر في الزوجة الشروط الموضوعية التي يقتضيها قانون جنسيتها، على أن أغلبية الفقه تشترط التطبيق الجامع فيما يتعلق بموانع الزواج لخطورتها.

استثناء:

إذا كانت المادة ١٢ من القانون المدني المصري قد وضعت القاعدة العامة للشروط الموضوعية في الزواج فأخضعها لقانون جنسية كل من الزوجين فقد جاءت المادة ١٤ باستثناء لهذه القاعدة مقتضاه " إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج . طبقاً لهذا النص إذا كان أحد الزوجين عند انعقاد الزواج يحمل الجنسية المصرية، فإن الشروط الموضوعية للزواج تخضع للقانون المصري وحده فيما عدا شروط الأهلية، فيجب أن تتوافر شرط الأهلية في الطرف الآخر طبقاً لقانون جنسيته، مثال ذلك إذا تزوج مصري بفرنسية فإن الزواج يخضع للقانون المصري من حيث كافة الشروط الموضوعية عدا شرط أهلية الزوجة فيخضع للقانون الفرنسي.

٤- أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية للزواج:

إذا أدت قاعدة التنازع الخاصة بالشروط الموضوعية للزواج، إلى عقد الاختصاص لقانون أجنبي معين، فإن ذلك لا ينفي حق القاضي في أن يستبعد أحكام هذا القانون، إذا تعارض تطبيقها مع النظام العام في دولته.

إذ أنه في فرنسا مثلاً، تعد الشروط الموضوعية للزواج من صميم المسائل التي تمس النظام العام هناك. أما في مصر، فإن الدور الذي تلعبه فكرة النظام العام في مجال الزواج دور ضئيل، ذلك أنه لا يوجد في مصر قانون موحد للأحوال الشخصية، فإلى جانب الشريعة الإسلامية، هناك الشرائع المالية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. ومن الحالات التي يؤخذ فيها بفكرة النظام العام كأداة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي، حالة قيام المانع الديني في الزواج، ومراعاة حقوق المسلم من اعتبار زواج المسلمة بغير المسلم باطلان ولو كان القانون الأجنبي يقرر صحته، واعتبار زواج المسلم بغير المسلمة صحيحاً.

⚖️ في خارج إطار حماية حقوق المسلمين، يبقى للنظام العام دور في مواد الزواج في مصر، كأداة لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي، إذا تعارضت أحكامه مع مبادئ الحرية والمساواة التي تسود المجتمع المصري. وعلى ذلك، لا يعتد القاضي المصري بموانع الزواج المبنية على اختلاف اللون أو الجنس، لتعارض ذلك والأسس الجوهرية في المجتمع المصري.

ه- الشروط الشكلية للزواج:

⚖️ يدخل في شروط الزواج الشكلية، كل ما يتعلق بالإجراءات، وبمسائل الاختصاص والمعاوضات التي تقدم فيه وإشهار الزواج، وشهوده، وتحرير عقده وإثباته. وتعتبر أغلب الدول المسيحية شهر الزواج في شكل ديني شرطاً شكلياً.

⚖️ الرأي السائد فقهاً وقضاءً، هو أن المراسم الدينية في البلاد الإسلامية تعتبر شروطاً شكلية في الزواج وليست موضوعية وعلى كل حال فيرجع في تكييف شروط الزواج، وما إذا كانت موضوعية أم شكلية، لقانون القاضي طبقاً للقاعدة العامة، والرأي السائد فقهاً وقضاءً، هو إخضاع الشروط الشكلية في الزواج لقانون المحل.

⚖️ متى تم الزواج في بلد طبقاً للشكل الذي يستلزمه قانون هذه البلد، وجب أن يعتبر صحيحاً لدى كل الدول، ولو كان لدى دول لا تعترف بصحة هذا الشكل في داخلها. فمثلاً لو تم زواج بين فرنسيين في اليونان في الشكل الديني الواجب هناك، وجب أن يعتبر هذا الزواج صحيحاً في فرنسا، مع أن هذا الشكل غير مقبول داخل فرنسا.

⚖️ لقد نصت المادة الخامسة من اتفاقية لاهي بقولها يعتبر الزواج الحاصل صحيحاً من حيث الشكل طبقاً لقانون البلد الذي يباشر فيه، صحيحاً في كل مكان آخر.

⚖️ بيد أن البلاد التي تعتبر الشكل الديني ركناً موضوعياً في الزواج مثل اليونان، لا تعترف بصحة زواج تم بين رعاياها في الخارج في غير الشكل الديني المطلوب. وقد أعطت اتفاقية لاهي لمثل هذه البلاد الحق في ذلك، فأضافت في المادة الخامسة ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه يجوز للبلاد التي يتطلب قانونها شكلاً دينياً للزواج، ألا تعترف بالزواج المعقود بين رعاياها في الخارج في غير الشكل الديني المطلوب.

⚖️ تجيز غالبية الدول اليوم لرجال السلك السياسي والقنصلي في الخارج، أن يقوموا بعقد زواج رعايا دولهم، ولو كان الشكل الذي يتم فيه الزواج مخالفاً لشكل الزواج في البلد الذي هم معتمدون لديه.

٦- الشروط الشكلية في القانون المصري:

⚖️ اقتصر القانون المدني المصري، على النص في المادة ١٢ الى إخضاع شروط الزواج الموضوعية لقانون كل من الزوجين، ولم يتعرض للشروط الشكلية في الزواج.

⚖️ القواعد العامة الخاصة بالشكل هي قواعد المادة ٢٠ مدني، وطبقاً لهذا النص يجوز أن تخضع الشروط الشكلية للزواج لقانون المحل كما يجوز أن تخضع لذات القانون الذي يسرى على شروط الزواج الموضوعية، ويجوز أيضاً أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أن كانا متحدين موطناً أو لقانون جنسيتهم أو اتحاداً جنسية والا فيعمل بالتطبيق الموزع.

⚖️ يترتب على ذلك أن للمصريين في الخارج أن يعقدوا زواجهم طبقاً للشكل المحلي للبلد الذي يتم فيه الزواج.

أ- **إذا كان هذا الشكل مدنياً وكان الزوجان مسلمين**، فإن زواجهما يكون مقبولا في القانون المصري، أما إذا

كان الشكل دينياً وكان الزوجان مصريان مسلمين، فلا يجوز لهما إجراء زواجهما في هذا الشكل.

ب- **إذا كان غير مسلمين** فهما إجراؤه في هذا الشكل وللمصريين أيضاً إجراء الزواج أمام رجال السلك القنصلي المصري في الخارج.

ج- **زواج الأجانب في مصر** فيجوز أن يتم في الشكل المحلي المصري، أو طبقاً لقانون جنسيتهم، أو أمام

قنصلياتهم أن كان لها ذلك، يتم الزواج في الشكل المحلي المصري أمام هيئات التوثيق

الاشكال المحلية للزواج في مصر

✎ يختص المأذونيين بتوثيق عقود زواج المصريين المسلمين فقط اما بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة فيتولي توثيق عقود زواجهم موظف مختص هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ لانه يكون ملم بالاحكام الدينية للجهة التي تولي التوثيق بها بينما تتولي مكاتب التوثيق الاختصاص بتوثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين غير المتحدي الملة والطائفة

✎ **قد قضت محكمة النقض في ذلك** ← بان مؤدي نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ علي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه واعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة او الطائفة وخولها لموثق منتدب له امام بالاحكام الدينية للجهة التي يتولي التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة

✎ **فيما يتعلق بزواج الاجانب** ← سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين فيتولي توثيقها مكتب توثيق عقود زواج الاجانب بوزارة العدل

✎ الشكل الدبلوماسي او القنصلي بالنسبة لزواج الاجانب في القنصلية التي ينتمون اليها بجنسيتهم اذا كانت قوانين الدول التابعين لها تخول لهم ذلك وعند اختلاف جنسية الزوجين فيتعين عقد الزواج امام الموظف المختص في كل من قنصلية الزوج والزوجة

٧- آثار الزواج :

أ- المقصود باثار الزواج :

✎ تترتب على الزواج آثار شخصية وآثار مالية ،

✎ **تتلخص الآثار الشخصية** في الشريعة الاسلامية ، في حل العشرة والاستمتاع بين الزوجين والطاعة ، ومن الآثار في القوانين الاوروبية المساكنة والاخلاص المتبادل والتعاون .

✎ **اثر الزواج بالنسبة للمال** ← ما يعرف بالنظام المالي للزوجين وهو نظام غير معروف في البلاد العربية والاسلامية ، التي يحتفظ فيها كل من الزوجين بحريته في ادارة امواله ، ويقصد بالنظام المالي للزوجين مجموعة القواعد القانونية او الاتفاقية التي تحدد حقوق وواجبات كل من الزوجين من حيث ملكية اموالهما وايرادات هذه الاموال وادارتها والانتفاع بها .

ب- ما هو القانون الذي يخضع له آثار الزواج :

✎ اخضع القانون المصري كل هذه الآثار الى **قانون جنسية الزوج عند ابرام عقد الزواج** ، فنصت المادة ١/١٣ على ما يلي : " يسرى قانون الدولة التي ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال " .

✎ بيد انه اذا كان هذا هو الاصل فإن المادة ١٤ قد ادخلت عليه استثناء فنصت على انه " اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصري وحده " .

✎ طبقا للقانون المصري الاصل ان اثار الزواج شخصية او مالية تخضع لقانون جنسية الزوج وقت ابرام عقد الزواج باعتبار ان الزوج هو رب الاسرة على انه اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج ، فإن القانون المصري وحده هو الذي يسرى ، وعلى ذلك فإن القانون المصري هو الذي يسرى على اثار الزواج ، اذا كانت الزوجة مصرية وقت انعقاد الزواج والزوج اجنبياً .

س ٨: وضع القانون الذي يحكم الطلاق والتطليق والتفريق والنفقة والميراث والوصية؟

رابعا: انعضاء الزواج

١- الطلاق والتطليق والتفريق :

- الطلاق ← نظام معروف فى الشريعة الاسلامية وبهت نقضى الرابطة الزوجية بإرادة احد الزوجين وهو الزوج فى الغالب .
- التطليق ← انهاء رابطة الزوجية بحكم القاضى بناء على توافر سبب من الاسباب المحددة فى القانون
- التفريق ← المباعدة بين الزوجين وهو نظام معمول به فى الدول التى لا تنتهى فيها رابطة الزواج الا بالوفاة .

٢- القانون الذى يحكم الطلاق والتطليق والتفريق :

القاعدة :

- يخضع الطلاق والتطليق والانفصال لقانون جنسية الزوج مع اختلاف فى الزمن ولما كان الطلاق يتم بإرادة الرجل فإن القانون الذى يسرى عليه هو القانون جنسية الزوج وقت الطلاق أى وقت اعلان ارادة الزوج الطلاق وبما ان التطليق والانفصال يتما بحكم قضائى فيسرى عليهما قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى .
- الواقع ان هذا الحكم يشكل ظلما بالنسبة الى الزوجة ، وكثيرا ما يؤدى الى تعسف الزوج ، فإذا تزوج شخصان تحت سلطة قانون يحرم الطلاق ، مثل القانون الايطالى فيكفى ان يغير الزوج جنسيته ويتجنس بجنسية دولة كفرنسا التى يقبل قانونها الطلاق ثم يرفع دعوى امام المحاكم الفرنسية طالبا التطليق طبقا لقانون جنسيته الجديدة .
- إجراءات التطليق والتفريق فهي تخضع لقانون القاضي ويجوز للرعايا المصريين فى الخارج أن يجروا الطلاق أمام القنصليات المصرية فقد منح قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لبعثات التمثيل القنصلي سلطة تحرير شهادات الطلاق وشهادات التصديق عليه .

الاستثناء المخصوص عليه فى المادة ١٤ :

- المادة ١٤ اوردت استثناء فقضت بأنه " اذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده " ، ومقتضى هذا الاستثناء انه اذا كان الزوج او الزوجة من رعايا مصر عند انعقاد الزواج ، فإن القانون المصرى هو وحده هو الذى يسرى على الطلاق او التطليق او التفريق .
- تظهر الصعوبة اذا كان احد الزوجين مصرياً عند انعقاد الزواج والزواج الآخر اجنبيا ، وبعد انعقاد الزواج اصبح الزوج المصرى هو الآخر اجنبيا ، فهل يخضع طلاق هذين الاجنبيين او تطليقهما او التفريق بينهما للقانون المصرى ، باعتبار ان احد الزوجين كان مصرياً وقت انعقاد الزواج ، على الرغم من ان الزوجين قد اصبحا اجنبيين ، يرى القضاء المصرى هذا رأى .
- بينما يرى بعض الفقهاء انه يلزم لتطبيق القانون المصرى فى هذه الحالة ان تكون الزوجة مصرية وقت الطلاق او وقت رفع دعوى التطليق او التفريق ونميل لتأييد رأى القضاء .

خامسا: النفقة بين الاقارب ، مضمونها والقانون الواجب التطبيق :

- ان النفقة المقصودة هنا هى الواجبة للاقارب والاصهار وقد نصت المادة (١٥) علي إخضاعها لقانون المدين بها فقالت : "يسرى علي الإلتزام بالنفقة فيما بين الأقارب المدين بها " المدين بالنفقة" وهو تعبير معيب لأنه يفترض مقدماً أن شخصاً معيناً مديناً بالنفقة في حين أن هذه المديونية لا يمكن معرفتها إلا بعد الرجوع إلي قانون جنسية هذا الشخص فقد لا يعتبره قانون الشخص مديناً بتلك النفقة وقد يعتبره كذلك وعلي أي الأحوال فإن التعبير الأفضل هو " المطلب بالنفقة" بدلاً من "المدين بالنفقة" ووفقاً للمادة (١٥) فإن قانون جنسية المدين بالنفقة أو قانون موطنه هو الذى يسرى علي إلتزامه بالنفقة نحو أقاربه أما في فرنسا فقد سار القضاء علي اعتبار القواعد القانونية المتعلقة بالنفقة تمس النظام العام ويجب أن تسري حتي علي الأجانب لإتصالها بالأمن العام .

⚖️ **النفقة الوقتية** التي يقضي بها القاضي أثناء نظر الدعوي **فتخضع لقانون القاضي** بإعتبار هذه النفقة الوقتية أجراء مؤقتاً يتعلق بالأمن العام في الدولة .

سادساً: حاية العَصْر :

⚖️ تنص المادة (١٦) من القانون المدني المصري "يسرى على **المسائل الموضوعية** الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة ، **قانون الشخص الذي تجب حمايته** ، وتخضع المسائل الموضوعية في هذا النظام لقانون ناقص الاهلية او الغائب ، لا لقانون جنسية القائم بالحماية ، وذلك لان الحماية مقررة لمصلحة ناقص الاهلية او الغائب" .
⚖️ **القواعد المتعلقة بالإجراءات** والإختصاص في هذه النظم فهي **تخضع لقانون القاضي** طبقاً لنص المادة (٢٢) مدني

الميراث والوصية :

⚖️ يسري علي الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الي ما بعد الموت قانون المورث او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته

اولاً : الميراث :

⚖️ ادخل القانون المصري والقوانين العربية الميراث في نطاق الاحوال الشخصية واخضعه كله سواء وقع على عقار او على منقول **لقانون جنسية المتوفى** ، وتفرق بعض التشريعات بين العقار والمنقول فتخضع الميراث في العقار لقانون موقعه والميراث في المنقول لقانون موطن المتوفى .
⚖️ **في مصر** فقد ايد جانب من الفقه المصري اخضاع الميراث لقانون الجنسية استنادا الى الصلة الوثيقة بينه وبين روابط الاسرة ، فضلا عن ان ذلك يؤدي الى وحدة القانون الواجب التطبيق على التركة كلها .
⚖️ على ان هناك جانبا آخر من الفقه المصري ، يرى ان وحدة القانون الذي تخضع له التركة ، يمكن ان تتحقق بغير تطبيق قانون جنسية المتوفى ، ويشير هذا الرأي الى وجوب تطبيق قانون موطن المتوفى على التركة منقولة كانت او عقارية علي أساس أن أموال الشخص غالباً ما توجد في الدولة التي يتوطن فيها ومهما يكن من أمر الخلاف السابق فقد حسمه المشرع وأخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى .

١- مجال تطبيق قانون جنسية المتوفى :

⚖️ يبين قانون جنسية المتوفى شروط استحقاق الارث ، وهي تدور حول موت المورث (حقيقة او حكما) وحياته الوارث ، وهل يشترط تحقيق حياة الوارث حقيقة وقت موت المورث ، ام يكفي تحقيق حياته حكما ، ويبين كذلك من هم الورثة ومرتبة كل منهم وانصبتهم وموانع الارث ، وحالات الحجب .
⚖️ **المسائل التي يتولى قانون جنسية المتوفى** تحديدها بيان الحقوق والالتزامات التي تنقل الى الورثة وكيفية انتقالها ووقته ففي الشريعة الاسلامية تنقل الحقوق دون الالتزامات الى الوارث ومن ثم لا يجوز التنفيذ على اموال الوارث وفاء لدين المورث .

٢- مدى تدخل قانون موقع المال :

⚖️ اذا كان المشرع المصري قد اخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى الا ان ثمة قيد هام يرد على تلك القاعدة ذلك ان الميراث يعتبر سببا من اسباب انتقال الحق العيني ، ومن ثم يجب ان يخضع للقانون الذي يحكم الاموال **وعلى ذلك فإن قانون موقع المال هو الذي يبين المسائل الاتية :**

١- مدى تعلق حقوق دائن المتوفى بأموال التركة بوصفها ضمانا لهذه الديون ، وعلى ذلك فالقانون المصري هو الذي ينطبق بالنسبة لقاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون ، ما دامت اموال التركة موجودة في مصر ولو كان المورث اجنبيا .

٢- شهر حق الارث بالنسبة للعقارات وتحديد الاثار المترتبة على هذا الشهر .

٣- يتولى قانون موقع المال تنظيم حالة الشيوع بين الورثة وكيفية ادارة اموال التركة الشائعة .

٣- حكم التركة الشاغرة :

قد يتوفى اجنبي عن تركة تتضمن اموالا موجودة فى مصر ويتضح من قانون جنسية المتوفى الا واث له ، او ان ورثته تنازلوا عن حقهم ، وفى ايلوله اموال التركة تتجه بعض التشريعات الى ايلولتها للدولة التى توجد فيها باعتبار ان الدولة هى وارث من لا وارث له ، وبعضها يتجه الى ايلولتها لدولة جنسية المتوفى او دولة موطن المتوفى .

س٩: وضع اثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية؟

اثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق فى شأن الميراث

إذا تبين ان القانون الواجب التطبيق على الميراث يتعارض مع النظام العام فى مصر ، فإنه يتعين استبعاد تطبيقه ، ويعتبر القانون الاجنبى مخالفا للنظام العام فى مصر ، اذا كان يمنع الميراث بسبب الجنس او اللون ، او يجيز الميراث لقاتل مورثه عمدا .

إذا كان القانون الاجنبى يتضمن احكاما تختلف عن الاحكام الواردة فى القانون الوطنى فإنه لا يترتب على ذلك استبعاد القانون الاجنبى بوصفه مخالفا للنظام العام ، الا اذا اصطدمت الاحكام الواردة به بالاسس الجوهرية التى يقوم عليها النظام القانونى الوطنى .

على ذلك فلو تضمن القانون الاجنبى ضمن موانع الارث **اختلاف اللون او الجنس** فإنه يصطدم بالنظام العام المصرى ويتعين لذلك استبعاد تطبيقه . غير أن الأمر يدق بالنسبة لميراث المسلمين وذلك فى حالة إختلاف القانون الأجنبي عن القانون المصرى المستند من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن بيان الورثة وأنصبتهم **فهل يعتبر القانون الأجنبي مخالفاً للنظام العام فى مصر؟** أختلف الفقه فى هذا الشأن فذهب البعض إلى أنه يتعين الإمتناع عن تطبيق القانون الأجنبي وذهب آخر إلى أنه لا يجوز إستبعاد ذلك القانون أو الإمتناع عن تطبيقه لمجرد حرمانه بعض الورثة أو تغيير أنصبتهم وذلك لأنه لا يؤثر فى النظام الإجتماعى المصرى أن بنت المتوفى حصلت على نصيب مواز لأبنه وقد أخذ القضاء بالرأى الأخير أما **الإجراءات والإختصاص** فيجري عليها **قانون القاضى** طبقاً لنص المادة ٢٢ مدنى .

ثانياً: الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت :

ادخل القانون المصرى الوصية ضمن الاحوال الشخصية ، ويسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت **قانون الميراث او الموصى** او من صدر منه التصرف وقت موته ، ومع ذلك **يسرى على شكل الوصية قانون الموصى** وقت الايصاء او قانون البلد الذى تمت فيه الوصية .

الوصية طبقاً للشريعة الإسلامية ← تصرف فى التركة يضاف الى ما بعد الموت ، وهى تنعقد عند صدورهما من الموصى ، ولكن يتوقف نفاذها على موته وقبول الموصى له .

لما كانت الوصية عمل ارادى لذلك يجب ان تتوافر لدى الموصى اهلية التبرع عند صدورهما ولذا فإن رأى السائد هو ان اهلية الموصى تخضع لقانون جنسيته وقت عمل الوصية .

قد ألحق القانون المدنى بالوصية تصرفات المريض مرض الموت المقصود بها التبرع ، فنصت المادة ١/٩٢٠ على ان " كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت " ، **اما شروط الوصية الشكلية فقد** اخضعها القانون المدنى المصرى **لقانون جنسية الموصى وقت الايصاء** ، او لقانون المحل الذى تتم فيه الوصية **ويلاحظ** أن التفرقة بين ما يعتبر من شروط الوصية موضوعياً وما يعتبر منها شكلياً مسألة تكييف تخضع لقانون القاضى طبقاً للقاعدة العامة ففى بعض البلاد مثل هولندا يحرم علي الهولنديين ولو فى الخارج عمل الوصية فى غير الشكل الرسمى بينما هو شرط شكلي عندنا وفى أغلب الدول فالوصية فى مصر تتم فى أى شكل سواء بالعبارة أو بالكتابة وسواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية بل ويجوز أن تتم الوصية بالإشارة المفهومة إذا كان الموصى عاجزاً عن التعبير وعن الكتابة أما أهلية الموصى له فإنها تخضع لقانون جنسيته وقت قبول الوصية .

أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق بشأن الوصية

إذا كان القانون الواجب التطبيق على الوصية أو التصرف المضاف إلى ما بعد الموت مخالفاً للنظام العام في مصر فإنه يتعين استبعاد تطبيقه ، كما لو كان يجوز استحقاق الموصى له للوصية ولو كان قاتلاً للموصى عمداً ، أما إذا كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق على الوصية يختلف عن القانون المصري بشأن الوصية المستند من الشريعة الإسلامية وهذا الاختلاف في القدر الجائز الإيصاء به لغير المسلمين ، فإن هذا لا يعتبر متعارضاً مع النظام العام في مصر ومن ثم يتعين تطبيق القانون الأجنبي وكذلك الشأن لو كان القانون الأجنبي لا يأخذ بنظام الوصية الواجبة المنصوص عليها في القانون المصري فإنه لا يعتبر مخالفاً للنظام العام حيث أن الوصية الواجبة مقررة لحماية الجماعة الوطنية .

الهبة :

تعتبر الهبة في القانون المصري من العقود المالية التي تخضع لقانون العقد وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .

القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية

أولاً : تعريف العقد الدولي ومعايير دولته

المقصود بالعقد الدولي هو العقد الذي تثار بمناسبته مشكلة تنازع القوانين وأغلب الفقه يطلق عليه العقد التجاري الدولي إلا أننا نفضل أن نطلق عليه تسمية العقد الدولي لأن المميز لهذا العقد هو صفته الدولية وليس صفته التجارية ولذلك نتعرض للمعايير التي قال به الفقه وأخذت بها القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن دولية العقد وهو ما نتناوله على النحو التالي :

العقد عموماً هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام كإبرام عقد من العقود أو نقله أو تعديله أو إنهاء ، وإذا كان العقد في مجال القانون الداخلي يلعب دوراً أساسياً في تبادل وتداول الثروات والخدمات بين أطرافه فإن هذا الدور يتعاظم وتزداد أهميته في مجال الروابط الدولية ووسيلة المبادلات الاقتصادية التي تتم عبر الحدود .

ما يفرق العقد الداخلي عن مفهوم العقد الدولي هو صفة الدولية التي تتوافر في هذا العقد الأخير لذلك كانت محاولات الفقه في تعريف العقد الدولي لم تتناول تعريف العقد ذاته وإنما حاولت تعريف وضبط صفة الدولية فيه نظراً لأن إضفاء تلك الصفة على العقد يترتب عليه إخراجها من نطاق طائفة العقود الداخلية **بما يفيد أمران**

الأمر الأول : إفلات العقد من نطاق تطبيق قانون وطني داخلي كان سيطبق عليه قسراً لو لم تتوافر له هذه الصفة .

الأمر الثاني : إخضاع العقد الأحكام ومبادئ قانونية متميزة عن تلك التي يخضع لها العقد الداخلي تراعي طبيعة الدولية في العقد من ذلك حرية اختيار الأطراف للقواعد القانونية التي يرغبون في تطبيقها سواء من ناحية الموضوع أو الإجراءات .

بالتالي لا تكون بصدد اختيار حقيقي للقانون الواجب التطبيق إلا في وجود عقد بالإضافة إلى أنه يشترط أن تتوافر صفة الدولية في هذا العقد لأن العقد الدولي هو الذي يثير مشكلة تنازع القوانين

تتحدد صفة الدولية في العقد وفقاً لأحد معيارين نتناولهما ثم نبين موقف الاتفاقيات الدولية من مسألة دولية العقد ؟

المعيار الأول: المعيار القانوني

يقوم المعيار القانوني على أساس أن العقد يعتبر دولياً إذا اتصلت أحد عناصره الرئيسية (الأطراف - المحل السبب) بأكثر من نظام قانوني واحد، بحيث إذا اشتمل على عنصر أجنبي سواء اتصل هذا العنصر بالأعمال المتعلقة بإبرامه أو تنفيذه أو بموطن المتعاقدين أو جنسيتهم فإنه بعد دولياً وفقاً لهذا المعيار

المعيار الثاني: المعيار الاقتصادي

يعرف العقد الدولي بأنه " العقد الذي يستتبع تحركات رؤوس الأموال والبضائع في شكل من أو جزر عبر الحدود الوطنية بما يجاوز الاقتصاد الوطني لأكثر من دولة وفقاً لما تقتضيه ضروريات ومصالح التجارة الدولية .

على ذلك يعتبر العقد دولياً إذا كان يستتبع حركة مد وجزر بتحركات رؤوس الأموال والبضائع عبر الحدود الوطنية لأكثر من دولة وذلك بالقيام بعمليات تصدير واستيراد للقيم الاقتصادية

ثانياً: القانون الذي يحكم موضوع العقد الدولي

الواجب التطبيق على موضوع العقد الدولي هو قانون الإرادة الذي يختاره المتعاقدين صراحة لحكم هذا العقد فإن لم يختار المتعاقدين صراحة لقانون دولة معينة يجب على القاضي المطروح أمامه النزاع الرجوع إلى الإرادة الضمنية للمتعاقدين وهو يستشف تلك الإرادة من خلال مسلك المتعاقدين وظروف التعاقد كاختيار المتعاقدين دولة معينة لتنفيذ عقدهم فيطبق قانون دولة محل تنفيذ العقد باعتباره قرينة عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين على أساس أن مصالح المتعاقدين ترتبط بدولة تنفيذ العقد أكثر من غيرها من الدول الأخرى المرتبطة بالعقد

لكن يثار التساؤل في حالة تعدد أماكن التنفيذ أو حالة عدم تحديد المتعاقدين مكان تنفيذ عقدهم في هذه الحالة يمكن الأخذ ببعض المؤشرات التي تساعد في الكشف عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين مثل اللغة التي حرر بها العقد

في كل الأحوال في حالة تعذر الوصول إلى الإرادة الضمنية للمتعاقدين فإن القاضي يلجأ إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدوا في الموطن فإن اختلف موطن كل منهما لجأ القاضي إلى تطبيق قانون دولة محل إبرام العقد .

ثالثاً: القانون الواجب التطبيق على شكل العقد الدولي

القانون الذي يحكم الشكل في العقود هو قانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك فالطابع التخييري لضوابط الاسناد يجعل خضوع العقد من حيث الشكل لأي قانون منهما صحيح على سبيل التخيير وليس على سبيل الترتيب والالزام

القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية

القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية هو قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام

المقصود بالالتزامات غير التعاقدية : تلك الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) وتلك الالتزامات الناشئة عن الفعل النافع (الإثراء بلا سبب) .

القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في مجال التحكيم التجاري الدولي

أن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في مجال التحكيم هو القانون الذي يتفق عليه المتعاقدان وفي حالة اختيار المتعاقدين لقانون دولة معينة فإن هيئة التحكيم تلتزم بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون المختار وليس قواعد التنازع فيه ، مما يعني رفض فكرة الإحالة في مجال التحكيم التجاري الدولي إلا إذا اتفق الأطراف على الأخذ بها وتطبيق قواعد التنازع في القانون المختار ولكن يجب في هذه الحالة أن يكن اتفاقهم صريح على الأخذ بالإحالة حيث إن الأخذ بفكرة الإحالة وتطبيق قواعد التنازع في القانون المختار من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق أحكام قانون دولة أخرى غير التي اختارها الأطراف مما قد يعرض الحكم الذي يصدره المحكم الإمكانية الطعن عليه بالبطلان لتطبيقه قانون غير القانون الذي انصرفت إليه إرادة الأطراف.

في حالة غياب اختيار المتعاقدين للقانون الذي يحكم موضوع نزاعهم تطبيق القانون الأكثر اتصالا بالنزاع الأمر الذي يعني ضرورة وجود صلة بين النزاع والقانون الذي تطبقه هيئة التحكيم والتي تمتلك سلطة تقديرية واسعة في البحث والكشف عن هذا القانون.

الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية

تنقسم قواعد الإختصاص إلى قسمين : قواعد إختصاص داخلي / قواعد إختصاص دولي .

قواعد الإختصاص الداخلي ← التي تحدد إختصاص كل محكمة من محاكم الدولة .

قواعد الإختصاص الدولي ← التي تحدد نصيب محاكم الدولة من ولاية القضاء إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى وهذا النوع من الإختصاص هو الذي تنظمه قواعد الإختصاص القضائي الدولي .

الأهمية العملية لقواعد الإختصاص القضائي الدولي :

تعتبر قواعد الإختصاص القضائي الدولي من الناحية العملية من أهم قواعد القانون الدولي الخاص ذلك أن تعيين المحكمة المختصة هو في الواقع الذي يحدد الحل النهائي للنزاع فتحديد القانون الواجب التطبيق علي النزاع يتوقف علي ما نقضي به قواعد التكيف وقواعد الإسناد في دولة القاضي المرفوع إليه النزاع وهذه القواعد تختلف من دولة إلي أخرى فقد يكيف قاضي دولة مسألة معينة علي أنها من الشكل ويكيف قاضي دولة أخرى ذات المسألة علي أنها من الأهلية مما يترتب عليه إختلاف قاعدة الإسناد وإختلاف الحكم النهائي في النزاع .

مبدأ عدم التلازم بين الإختصاص القضائي والإختصاص التشريعي :

إذا كان تعيين القانون الواجب التطبيق أي تعيين الإختصاص التشريعي يتأثر بتحديد الإختصاص القضائي ، فإن ذلك لا يعني وجود تلازم بين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق علي النزاع ، فتحديد المحكمة المختصة لا يستتبع حتماً تطبيق قانون المحكمة علي موضوع النزاع فالقاضي المطروح عليه النزاع يلجأ الي قواعد الاسناد في قانونه لتعيين القانون الواجب التطبيق وهذه القواعد قد تشير الي تطبيق قانون دولة غير دولة القاضي والواقع ان عدم التلازم بين الإختصاص القضائي والإختصاص التشريعي شرط اساسي لقيام ظاهرة تنازع القوانين اذ لو طبقت المحكمة المختصة بنظر النزاع قانونها مباشرة علي موضوع نزاع لما وجد مجال لأي تنازع .

الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية

س ١٠: اكتب في الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من القانون المقارن؟

الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من القانون المقارن

الحالة الاولى: اختصاص محكمة موطن او إقامة المدعي عليه:

تقضي المادة ٢٩ من قانون المرافعات الصادر في ٩ مايو سنة ١٩٦٨ بأنه تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الاجنبي الذي له موطن او محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

يتبين من النص ان المشرع يعقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية بالنسبة للاجانب المدعي عليهم إذا كان لهم موطن أو محل إقامة بالجمهورية.

يشمل تعبير الموطن -كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- كلا من الموطن العام والموطن الخاص

الموطن العام ← المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة .

الموطن الخاص ← المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة أو يعد هذا المكان موطناً له بالنسبة الي اعماله المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة

الواقع ان تقرير المشرع باختصاص محاكم الجمهورية بناء علي توطن المدعي يتفق كما سبق ان أوضحناه مع المبادئ التي استقر عليها العمل في تشريعات مختلف الدول. غير أن المشرع لم يكتف بضابط الموطن في عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية بل اعتبر مجرد كون الجمهورية محلاً لإقامة المدعي عليه الاجنبي اساساً كافياً لاختصاص محاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع عليه.

قد جعل المشرع اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى التي ترفع علي الاجنبي المقيم او المتوطن بها اختصاصاً عاماً يسري بالنسبة لجميع الدعاوى التي ترفع عليه ولم يستثن من ذلك سوى حالة واحدة وهي ان تكون الدعوى عقارية متعلقة بعقار واقع خارج إقليم الجمهورية. إذ رأي المشرع ان محاكم الدولة الاجنبية الكائن بإقليمها العقار ستكون مما لا شك فيه أكثر قدرة علي البت في النزاع ومن ثم نص علي عدم اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة بالرغم من توطن او إقامة المدعي عليه بإقليم الجمهورية.

الحالة الثانية: اختصاص محكمة موقع اطلال:

نص المشرع في المادة ٢/٣٠ من قانون المرافعات علي اختصاص محاكم الجمهورية بالدعاوى المتعلقة بمال موجود بالجمهورية وتختص المحاكم المصرية في هذه الحالة حتي ولو لم يكن للمدعي عليه موطن او محل إقامة في مصر وقد جاء هذا النص عاماً بحيث يشمل جميع الدعاوى التي تتصل بمنقول او بعقار موجود في مصر وذلك بغض النظر عن طبيعة النزاع وسواء كانت الدعوى شخصية أم عينية أم مختلطة.

الحالة الثالثة: اختصاص محكمة محل الالتزام:

تنص المادة ٢/٣٠ علي اختصاص محاكم الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بالالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه.

علي ذلك تختص المحاكم المصرية بجميع الدعاوى العينية او الشخصية او المختلطة التي ترفع علي أجنبي حتي ولو لم يكن له موطن او محل إقامة في مصر إذا كان موضوع النزاع يتصل بالالتزام نشأ فيها بغض النظر عما إذا كان الالتزام **تعاقدياً أم تقصيرياً** كما تختص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتزامات يكون الإقليم المصري محلاً لتنفيذها سواء تم التنفيذ فعلاً او كان يتعين تنفيذه.

هناك صلة واضحة بني هذه الدعاوى وإقليم جمهورية مصر العربية مما يبرر عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية كما ان هذه المحاكم تستطيع كفالة آثار حكمها.

الحالة الرابعة: اختصاص المحاكم المصرية إذا كان المدعي عليه منمنعا جنسية جمهورية مصر العربية:

قانون المرافعات الجديد نص صراحة في المادة ٢٨ منه علي اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولم يكن له موطن أو محل إقامة بالجمهورية.

قد استثنى المشرع في هذا النص الدعاوى المتعلقة بعقار كائن خارج الجمهورية فقرر عدم اختصاص محاكم الجمهورية بنظرها، نظرا لما تتطلبه هذه الدعاوى من إجراءات ومعاينات تكون محكمة الدولة الكائن بها العقار أقدر علي الفصل فيها.

الحالة الخامسة: الخضوع الاختياري:

حرص المشرع في المادة ٣٢ من قانون المرافعات علي النص علي اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع امامها ولو لم تكن داخله اصلا في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها ولم يتطلب المشرع لانعقاد المحكمة ان يكون قبول المدعي عليه صريحا بل اكتفي بالقبول الضمني كأن يقبل مثلا الترافع امام المحكمة دون ان يدفع بعدم الاختصاص.

قد جعل المشرع اختصاص المحكمة في هذه الحالة اختصاصا عاما بحيث يسري علي جميع الدعاوى سواء كانت عينية ام شخصية ام مختلطة.

الحالة السادسة: الاختصاص بالطلبات العارضة او المؤقتة:

حرص المشرع عند قيامه بوضع قانون المرافعات الجديد علي الاخذ بالقاعدة التي استقر عليها العمل في القانون المقارن، والتي مقتضاها اختصاص محكمة الدولة بنظر الطلبات التي تربط بدعوى أصلية مرفوعة إليها.

نص في المادة ٣٣ من قانون المرافعات علي انه إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلية في اختصاصها تكون هذه المحاكمة مختصة بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة علي الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.

يتبين من هذا النص أولاً: انه إذا كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها فأنها تختص أيضا بالفعل في جميع المسائل الاولية التي يتعين البت فيها حتي يمكن الفصل في النزاع الاصيل وذلك حتي ولو لم يكن النظر في هذه المسألة الاولية يدخل اصلا في اختصاصها إذا رفعت أمامها إستقلالاً.

الحالة السابعة: الاختصاص بالإجراءات الوقفية والحفظية:

نص المشرع صراحة في المادة ٣٤ علي انه تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقفية والحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية ويتبين من هذا النص ان القاضي الوطني يستطيع الامر بالاجراءات الوقفية والحفظية التي يراد تنفيذها بالاقليم المصري.

الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من طبيعة النزاع

س ١١: اكتب في حالات الاختصاص القضائي الدولي المبني علي اسس مستمدة من طبيعة

الحالة الاولى: الدعاوى المتعلقة بإفلاس أشهر بالجمهورية:

من المعلوم ان التاجر ان توقف جزئيا او كلياً عن دفع دينه فإن صاحب المصلحة يستطيع ان يرفع دعوى يشهر بها إفلاسه وتختص محاكم الجمهورية بشهر الإفلاس في المنازعات ذات الطابع الدولي وفقا للقواعد السابق بيانها غير انه قد يرتب علي الحكم بالافلاس من محاكم الجمهورية العديد من المنازعات المتعلقة بأموال المفلس وتصفيته ويستلزم البت فيها الالتجاء إلي القضاء وقد رأي المشرع عند وضعه لقانون المرافعات الجديد أن يجعل المحاكم المصرية تختص بجميع هذه المنازعات تحقيقا لمصلحة العدالة وتيسيرا لحسن سير القضاء. فلا شك ان المحاكم المصرية -وهي المحاكم التي أصدرت الحكم بالافلاس- اقدر علي الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة به سواء رفعت من السنديك علي الغير ام من الغير علي السنديك وذلك دون التقييد بالمبادئ السابق بيانها في تحديد الاختصاص القضائي الدولي.

علي ذلك لا يشترط لاختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة ان يكون للمدعي عليه موطن او محل إقامة بمصر كما لا يشترط ان يكون المال محل النزاع كائنا بالاقليم المصري او أن يكون محل الالتزام بمصر بل انه لا يشترط كون المدعي عليه متمتعاً بجنسية الجمهورية إذ يكفي لانعقاد الاختصاص لمحاكم الجمهورية التأكد من ان شهر الافلاس قد صدر من محاكم جمهورية مصر العربية.

الحالة الثانية: الدعاوى المتعلقة بالزواج:

لما كان الزواج من المسائل الوثيقة الصلة بالشخص فقد رأي المشرع تحقيقاً لحسن سير العدالة وتيسراً علي الخصوم ان يستثني بعض الدعاوى المتصلة بالزواج من الخضوع للقواعد السابق بيانها في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الجمهورية وذلك علي التفصيل الاتي:

أولاً: دعاوى المعارضة في عقد الزواج :

رأي المشرع انه اذا كان عقد الزواج المراد إبرامه يدخل في اختصاص موثق مصري وفقاً لقواعد تنازع القوانين فإن المعارضة في هذا الزواج يتعين ان تختص بنظرها ايضاً محاكم الجمهورية.

الواقع ان تقرير مثل هذا المبدأ يؤدي الي حسن سير العدالة فقد لا يكون هناك سبيل من الناحية القانونية لمنع هذا الزواج الا عن طريق صدور حكم قضائي ولا شك ان محاكم الجمهورية أقدر علي إصدار مثل هذا الحكم نظراً لان الزواج سيبرم أمام موثق ينتمي الي الدولة ويخضع لسلطان محاطمها وهذا فضلاً عن انه في النص علي اختصاص محاكم الجمهورية تيسير لصاحب الحق قانوناً في الاعتراض إذ سيجنبه الالتجاء الي محاكم دولة موطن المدعي عليه.

ثانياً: الدعاوى المتعلقة بطلب فسخ زواج او بالتطليق او بالانفصال :

رأي المشرع حماية ثلاث طوائف من الزوجات وتمكينهن من رفع دعاوهن المتعلقة بفسخ الزواج او التطليق او الانفصال امام المحاكم المصرية وذلك بالرغم من عدم توطن او إقامة الزوج المدعي عليه بالاقليم المصري.

الطائفة الاولى: طائفة الزوجات الاتي كن يتمتعن بجنسية جمهورية مصر العربية وفقدن هذه الجنسية بالزواج:

قد رأي المشرع في المادة ٤/٣٠ السماح لهذه الطائفة برفع دعوى الطلاق او التطليق او الفسخ علي ازواجهن امام محاكم الجمهورية إذا كن متوطنات بإقليم الجمهورية وذلك دون ان يشترط وجوب توطن او إقامة الزوج المدعي عليه بإقليم الجمهورية. ويهدف المشرع بهذا النص كما يستفاد من المذكرة الايضاحية انه يمكن الزوجة التي كانت مصرية والمتوطنة بالجمهورية من إسترداد جنسية جمهورية مصر العربية بعد حصولها علي حكم قضائي لصالحها.

الطائفة الثانية: طائفة الزوجات الاتي هجرهن ازواجهن وتوطنوا خارج الجمهورية:

قد رأي المشرع في المادة ٤/٣٠ السماح لهؤلاء الزوجات برفع الدعاوى المتعلقة بفسخ الزواج او الانفصال او التطليق امام محاكم الجمهورية حتي بالرغم من توطن المدعي عليه بالخارج. لكن يشترط لإعمال هذا النص ان تكون الزوجة متوطنة بإقليم الجمهورية وذلك دون النظر الي الجنسية التي تتمتع بها فيستوي في هذا الصدد ان تكون الزوجة مصرية ام اجنبية. الواقع ان في النص علي اختصاص محاكم الجمهورية بالنسبة لهذه الدعاوى تيسير علي الزوجة التي هجرها زوجها ورعاية لمصلحتها إذ قد يتعذر عليها لظروف إجتماعية وإقتصادية الإلتجاء الي محكمة دولة موطن الزوج المدعي عليه ومقاضاته أمامها.

الطائفة الثالثة : طائفة الزوجات المتوطنات بإقليم الجمهورية الاتي ابعد ازواجهن عن إقليم الجمهورية:

قد رأي المشرع حماية لمصالحهن ان يعقد اختصاص لمحاكم الجمهورية إذا كان الزوج قد ابعد عن إقليم الجمهورية وتشترط للاختصاص في هذه الحالة كما هو الشأن بالنسبة للحالة السابقة ان تكون الدعوى متعلقة بفسخ زواج او انفصال او تطليق وان تكون الزوجة متوطنة بإقليم الجمهورية وذلك دون النظر الي جنسيتها.

الحالة الثالثة: دعاوى النفقة:

نص المشرع في المادة ٥/٣٠ على إختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة بالجمهورية اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او الزوجه متى كان لها موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها.

راي المشرع ضعف حالة المطالب بالنفقة وحاجته الي الرعاية فخرج عن القاعدة المعروفة في الإختصاص القضائي الدولي والتي تقضي بإختصاص محاكم الجمهورية إذا كان للمدعي عليه موطن او محل إقامة بالجمهورية وذلك في الحالتين الآتيتين:

الاولي ← تتعلق بدعاوى النفقة التي تقام من ام او زوجه لها موطن بجمهورية مصر العربية فقد اعتد المشرع بتوطن الام او الزوجة في اقليم الجمهورية وقرر إختصاص محاكم الجمهورية بدعاوى النفقة التي ترفع من اي منهما وذلك حماية لمصلحتهما. ولم يجعل المشرع لجنسية الام او الزوجة اي اثر بالنسبة لاختصاص محاكم الجمهورية كما لم يجعل لموطن او لمحل إقامة المدعي عليه اي اثر في الاختصاص.

الثانية ← تشمل دعاوى النفقة التي تقام من الصغير فقرر إختصاص محاكم الجمهورية في هذه الحالة حتي ولو لم يكن المدعي عليه المطالب بالنفقة مقيما ومتوطنا بالجمهورية غير ان المشرع قد اكتفي لإمكان إختصاص محاكم الجمهورية بدعوى الصغير ان يكون مقيما بإقليم الجمهورية وذلك علي خلاف الشأن بالنسبة لدعاوى النفقة المقامة من الام او الزوجه حيث تطلب المشرع التوطن باقليم الجمهورية.

الحالة الرابعة: دعاوى النسب:

نص المشرع في المادة ٦/٣٠ علي إختصاص محاكم الجمهورية بجميع دعاوى النسب إذا كان الصغير المراد اثبات نسبة مقيما بالجمهورية وبذلك لا يشترط محاكم الجمهورية ان يكون المدعي عليه متوطنا او مقيما بها بل يكفي لإنعقاد الإختصاص مجرد إقامة صغيرة بها وذلك دون النظر الي موطن الصغير او الي الجنسية التي يتمتع بها، فالصغير هو صاحب المصلحة الحقيقية في الدعوى ومن ثم يتعين مراعاة لقصره الا نضطره الي الالتجاء الي محاكم الدولة الاجنبية التي يتوطن بها المدعي عليه.

الحالة الخامسة: دعاوى الولاية:

رأي المشرع استثناء جميع الدعاوى المتعلقة بالولاية من قاعدة إختصاص محاكم الجمهورية الذي يبني علي اساس توطن او محل إقامة المدعي عليه غير ان المشرع فرق في هذا الصدد بين الدعاوى المتعلقة بالولاية علي النفس وتلك الخاصة بالولاية علي المال.

بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالولاية علي النفس فقد نص المشرع صراحة في المادة ٦/٣٠ علي اختصاص محاكم الجمهورية بجميع دعاوى الولاية علي النفس إذا كان الصغير مقيما بالجمهورية ويستوي في هذا الصدد ان يكون الغرض من دعوى الولاية سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إستردادها ويستوي كذلك ان يكون الصغير متمتعا بجنسية الجمهورية او اجنبيا عنها بل يستوي في هذا الصدد ان يكون المدعي عليه متوطنا او مقيما بالجمهورية فالعبرة فقط بكون الجمهورية محلا لإقامة الصغير حتي ولو لم يكن له موطن بها ووما لا شك فيه انه في إختصاص محاكم الجمهورية بمثل هذه الدعاوى مراعاة لظروف الصغير صاحب المصلحة الحقيقية في الدعوى.

بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالولاية علي المال فقد نص المشرع علي إختصاص محاكم الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية علي المال متى كان للقاصر او المطلوب مساعدته قضائيا موطن او محل إقامة الجمهورية الغائب.

يتبين من هذا النص ان محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالولاية علي المال، إذا كان مالك المال متوطنا او مقيما في الجمهورية. ويستوي في هذا الصدد ان تكون الدعوى المتعلقة بالولاية علي المال المرفوعة من المالك او مرفوعة ضده. طذلك يستوي ان يكون المالك قاصرا او مطلوب الحجر عليه ام غائبا فالعبرة فقط لاختصاص محاكم الجمهورية بكون المالك مقيما او متوطنا بأقليم الجمهورية.

🏛️ **جدير بالذكر** ان قانون المرافعات القديم اخذ بهذا ايضا في المادة ٨٦١ غير ان هذا القانون كان يقصر الاختصاص بالنسبة لدعاوى الولاية علي المال علي حالة توطن مالك المال بإقليم الدولة ولم يكن يقر إختصاص المحاكم إذا كان المالك مقيما فقط بإقليم الدولة وذلك علي خلاف الشان بالنسبة للمادة ٨/٣٣ من قانون المرافعات الجديد التي تعتد بكل من الإقامة والموطن لاختصاص محاكم الجمهورية.

س ١٢ : ما هي حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالميراث؟

الحالة السادسة: دعاوى الارث والتركات:

🏛️ لاحظ المشرع عند تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الجمهورية الصلة الوثيقة بين الدعاوى التي ترفع بشأن أرث او تركة والاقليم المصري ومن ثم رأي ان يجمع بينها في صعيد واحد من حيث الإختصاص فلم يعتد في تقريره إختصاص محاكم الجمهورية بمحل إقامة او توطن المدعي عليه كما لم يعتد بصفة المدعي وكونه وارثا ام من الغير كذلك لم يعتد بسبب الدعوى وكونها تتعلق بالمطالبة بحق في الارث او بدين علي التركة او بقسمتها او بإدارتها وإنما إشتراط فقط لإختصاص محاكم الجمهورية بجميع الدعاوى المتعلقة بالارث او التركة توافر **احد شروط ثلاث تضمنتهم المادة ٣١ علي سبيل الحصر:**

🏛️ **الحالة الاولى** **ان تكون التركة قد افتتحت بجمهورية مصر العربية** وتعتبر التركة قد افتتحت بالجمهورية إذا كانت الجمهورية هي اخر موطن للمورث.

🏛️ **الحالة الثانية** **ان يكون المورث مصري** ويرجع في تحديد جنسية المورث الي احكام تشريع الجنسية في جمهورية مصر العربية.

🏛️ **الحالة الثالثة** **ان توجد اموال التركة كلها او بعضها بإقليم الجمهورية** ويستوي في هذا الصدد ان يكون المال الموجود بإقليم الجمهورية منقولاً ام عقاراً.

مدي سريان الاستثناء المقرر في المادة ٢٨ و ٢٩ مرافعات علي دعاوي الميراث (الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار يقع خارج مصر :

🏛️ **نفق بين حالتين :**

١. وجود جميع اموال التركة العقارية في الخارج والاموال المنقولة في مصر فهنا لا تختص المحاكم المصرية بالاموال العقارية الموجودة في الخارج الا اذا قررت محكمة موقع العقار عدم اختصاصها ويقتصر اختصاص المحاكم المصرية علي اموال التركة الموجودة في مصر

٢. وجود بعض اموال التركة العقارية خارج مصر والبعض الاخر في مصر في هذا الفرض لا تختص المحكمة المصرية الا بالاموال الموجودة في مصر دون التي تقع في الخارج الا في حالة رفض محكمة موقع العقار الاجنبية الفصل في النزاع او ان تكون غير مختصة وكان العقار يملكه شخص مصري الجنسية

🏛️ بناء علي ذلك نري ان الاستثناء المقرر في المادة ٢٨ و ٢٩ يمتد سريانه علي دعاوي الارث والتركات باعتباره استثناء عام لكفالة تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المصرية في الخارج

🏛️ علي ذلك إذا توافر اي من الشروط الثلاث السابقة اختصت المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالارث او التركة.

الحالة السابعة: الدعاوى المتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بوجه عام:

🏛️ تنص المادة ٧/٣٠ مرافعات علي ان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية اذا كانت الدعوى متعلقة بمألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً او كان اجنبياً له موطن في الجمهورية وذلك اذا لم يكن للمدعي عيله موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوي

🏛️ قد قرر المشرع حالتان لاختصاص المحاكم المصرية وفقاً لهذا النص الغرض منها تلافي انكار العدالة في الاولى اما الثانية قائمة علي اساس القانون الواجب التطبيق في الدعوي

الحالة الأولى: اختصاص المحاكم المصرية القائم علي فكرة تجنب انكار العدالة

يشترط الاختصاص المحكمة المصرية وفقاً لهذه الحالة :

- ١- ان يكون النزاع متعلق باحدي مسائل الاحوال الشخصية
- يرجع في تحديد المقصود بالاحوال الشخصية لقانون القاضي لاعتبارها مسألة تكييف يتوقف عليها تحديد اختصاص المحكمة وتشمل الاحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم او المتعلقة بنظام الاسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والاقرار بالأبوة وانكارها والعلاقة بين الاصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والاصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة وكذلك المنازعات المتعلقة بالمواريث والوصاية
- ٢- ان يكون المدعي مصري الجنسية او اجني له موطن في مصر
- ٣- ان يكون المدعي عليه اجنبياً ليس له موطن او محل اقامة في مصر لأن لو كان للمدعي عليه موطن او اقامة في مصر لكانت المحكمة المصرية مختصة وفقاً لنص المادة ٢٩
- ٤- الا يكون للمدعي عليه موطن معروف في الخارج
- يمثل هذا الشرط الغرض من هذه الحالة وهي تجنب انكار العدالة حيث ان المدعي عليه ليس له موطن في مصر وكذلك ليس له موطن معروف في الخارج فكيف يمكن للمدعي الحصول علي حقه والحماية القضائية له فواجب الدولة هو اداء العدالة نحو مواطنيها وكذلك للمواطنين فيها

الحالة الثانية : الاختصاص القائم علي اساس ان القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق في الدعوي :

شروط اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة :

- ١- ان يكون النزاع متعلق باحدي مسائل الاحوال الشخصية
- ٢- ان يكون المدعي مصري الجنسية او اجني له موطن في مصر
- ٣- ان يكون المدعي عليه اجنبياً ليس له موطن او محل اقامة في مصر لأن لو كان للمدعي عليه موطن في مصر لكانت المحكمة المصرية مختصة
- ٤- ان يكون القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق علي النزاع
- يمثل هذا الشرط احدي حالات جلب الاختصاص التشريعي للإختصاص القضائي حيث ان القانون الواجب التطبيق في الدعوي يعد احد شروط اختصاص المحكمة ويقرر اختصاص المحكمة المصرية في ذلك انها الاقدر علي تطبيق القانون المصري في مسائل الاحوال الشخصية من اي محكمة اجنبية فضلاً عن انه من المرغوب فيه ان تكفل محاكم الدولة تطبيق قانونها بنفسها .

النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الاجنبية في القانون المصري

س ١٣ : وضع اهمية الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها؟

اهمية الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها:

يرتبط موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية ارتباطاً وثيقاً بموضوع الاختصاص القضائي الدولي، فحيث تستقل كل دولة بتنظيم حالات الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية بنظر المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي، فإذا عُقد الاختصاص بناء على ذلك لمحاكم دولة معينة فإن الحكم الصادر من قضاء هذه الدولة قد يطلب الاعتراف به وتنفيذه داخل حدود الدولة التي أصدرته، فلا توجد مشكلة في هذا الفرض حيث تقوم السلطات المختصة في الدولة بتنفيذ هذا الحكم شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الوطنية الأخرى الصادرة عن محاكم الدولة.

لكن تبدو الصعوبة في حالة طلب الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه في دولة أخرى غير تلك الدولة التي أصدرته، ففي هذا الفرض تستقل سلطة الحكم عن سلطة تنفيذه، حيث يصدر الحكم باسم السيادة الوطنية لدولة معينة، وتعمل على تنفيذه سلطة التنفيذ في دولة أخرى، فخضوع كل سلطة لسيادة دولة معينة يثير التساؤل عن مدى قابلية الحكم الصادر عن دولة معينة للاعتراف به وتنفيذه في دولة أخرى غير التي أصدرته؟

الإجابة على هاذ التساؤل تقتضي بأن يأخذ في حسابان اعتباران:

⚖️ **الاعتبار الأول** ← أن الاعتراف المطلق بالأحكام الأجنبية وتنفيذها شأنها شأن الأحكام الوطنية إنما يعني في حقيقة الأمر خضوع دولة التنفيذ لسيادة الدولة التي أصدرت الحكم وهو ما يتنافى مع اعتبارات السيادة والاستقلال التي تتمتع بها كل دولة.

⚖️ **الاعتبار الثاني** ← ويتمثل في أن الرفض المطلق للاعتراف بالأحكام الأجنبية ورفض تنفيذها بصورة مطلقة هو أمر يخل بالمعاملات الدولية من حيث تسييرها ومن حيث الاستقرار الواجب لها حيث سيضطر ذوي الشأن إلى رفع دعوى بالحق الثابت لهم في كل دولة تثبت حقوقهم فيها، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع الوقت وزيادة مصاريف التقاضي بل وقد يؤدي إلى تضارب الأحكام.

⚖️ **مثال ذلك** ← الحكم الصادر لصالح الدائن ضد مدينه من محاكم دولة معينة ولا تكفي أموال المدين الموجودة في هذه الدولة للوفاء بديونه الأمر الذي يدفع الدائن إلى رفع دعوى جديدة أما محاكم دولة أخرى توجد بها أموال للمدين حتى يتمكن الدائن من استيفاء باقي حقه.

⚖️ كذلك إذا صدر حكم بالتعويض من المحاكم المصرية ضد ألماني تتركز أمواله في ألمانيا فلا قيمة لهذا الحكم إذا لم تعترف به هذه الدولة الأخيرة بحجة كونه حكم أجنبي غير صادر من محاكمها.

⚖️ الأمر الذي يعني في النهاية عدم فائدة قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي فامتناع الدولة الوطنية من الاعتراف بالأحكام الأجنبية ورفض تنفيذها من شأنه أن يؤدي إلى امتناع الدول الأجنبية هي الأخرى عن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الدولة الوطنية من باب المعاملة بالمثل .

⚖️ ستكون القاعدة بالتالي هي أن الحكم الصادر في دولة ما يكون قابل للاعتراف به وتنفيذه داخل حدود تلك الدولة التي أصدرته فقط، ولا يكون له أي أثر خارجها بما يضر بمصالح المعاملات الدولية، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة وأهداف القانون الدولي الخاص المعاصر والتي ترمي قواعده إلى التعاون والتنسيق بين الدول.

⚖️ لذلك تسعى غالبية دول العالم إلى التوفيق والموازنة بين الاعتبارين السابقين بحيث لا يتم إهدار قيمة الحكم الأجنبي كلياً بإنكاره وعدم الاعتراف به. كما يصعب في نفس الوقت معاملته معاملة الأحكام الوطنية من ناحية أخرى ولذلك فإن مسلك غالبية الدول يسعى إلى احترام سيادة دولة تنفيذ الحكم من خلال عدم تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية إلا وفقاً للقيود والشروط التي تضعها دولة تنفيذ هذه الأحكام على أساس أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية تتسم بطابع وطني مستمد من النصوص الوطنية التي تحدد شروط هذا التنفيذ.

⚖️ **قد تناول المشرع المصري بيان هذه الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية**

س ٤١ : اكتب في الشروط الموضوعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية ؟

الشروط الموضوعية المطلوبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

⚖️ حتى يمكن تنفيذ الحكم الصادر في بلد أجنبي داخل الأراضي المصرية فإنه يلزم توافر بعض الشروط المتعلقة بالناحية الموضوعية للحكم المارء تنفيذه في مصر وتتمثل هذه الشروط في أن يكون الحكم أجنبياً وأن يكون صادراً في منازعة ذات طابع خاص وهو ما نتناوله في فرعين على النحو التالي.

الشرط الأول: أن يكون الحكم أجنبياً

⚖️ يتضمن هذا الشرط في حقيقة الأمر عنصرين الأول هو أن نكون بصدد حكماً والثاني أن تلحق الصفة الأجنبية بهذا الحكم .

أولاً: أن تكون بصدد حكم:

اختلف الفقه في تحديد المقصود بالحكم في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية ويمكن حصر هذا الخلاف في اتجاهين:

الاتجاه الأول ← يقصر أصحاب هذا الاتجاه صفة الحكم على ما يصدر عن السلطة القضائية في الدولة سواء عند استخدام سلطتها القضائية أو عند مباشرة وظيفتها الولائية **ولذلك يقصد بالحكم** وفقاً لهذا الاتجاه "كل قرار تصدره المحاكم في خصومة أو في غير خصوم ولو لم يكن فاصلاً في نزاع". ووفقاً لهذا التعريف فإن الحكم بمعناه العام يشمل ما تصدره المحاكم من أحكام بالمعنى الدقيق أثناء مباشرة سلطتها القضائية وهو ما يعرف **بالحكم القضائي** والذي يشترط فيه أن تكون هناك خصومة قائمة بين طرفين فيدعو أحدهما الآخر إلى ساحة القضاء ويترافعان ثم يصدر حكم في الخصومة فاصلاً للنزاع.

كما يشمل كذلك الأعمال الولائية ← عبارة عن القرارات التي تصدرها المحاكم وهي تباشر وظيفتها الولائي ولو لم تكن صادرة في غير خصوم أو كانت غير فاصلة في النزاع مثال ذلك إثبات الإقرار ببنوة الولد الطبيعي، والقرار الصادر بتعيين وصي أو الإذن ببيع مال القاصر .

الاتجاه الثاني ← وهو **الراجح** عندنا ويوسع أصحاب هذا الاتجاه في تحديد المقصود بالحكم بحيث **لا يقتصر**

عن ما يصدر عن السلطة القضائية فقط وإنما يشمل كذلك الأحكام الصادرة عن السلطة العامة في الدولة ولو لم تكن هي السلطة القضائية ما دامت قد خولت اختصاصات السلطة القضائية وفقاً للنظام القانوني السائد في الدولة وعلى ذلك فإن ما يصدر عن مجرد هيئة إدارية أو دينية في دولة ما تتمتع بسلطة إصدار الأحكام وفقاً للنظام القانوني السائد في الدولة، التي تتبعها هذه الهيئات تعد أحكاماً وإن كان الغالب هو تمتع السلطة القضائية في الدولة بذلك.

يرجع في تحديد المقصود بالحكم لقانون القاضي الذي يطلب منه التنفيذ باعتباره مسألة تكييف وفقاً لنص المادة ١٠ من القانون المدني المصري، بمعنى أنه يعتبر حكماً ما يعد كذلك وفقاً لقانون دولة القاضي الذي يطلب إليه التنفيذ .

بالرجوع لأحكام القانون المصري نجده قد ساوى بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية بين الأحكام والأوامر الأجنبية، وأخضع كلا منهما لنفس الشروط المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية ، كما تسري نفس الأحكام على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

كذلك فإن السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية المحررة في مصر، وذلك بعد التحقق من توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه وبعد التأكد من خلوه مما يخالف النظام العام في مصر .

ثانياً: أن تلحق الصفة الأجنبية بالحكم:

يذهب بعض الفقه إلى أن الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الصادر في بلد أجنبي وهو ما يستفاد من نص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات والتي تنص على أنه **"الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي** يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه".

المعنى السائد في ظل الدول التي تأخذ بالنظام الأنجلو أمريكي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ووفقاً لهذا الرأي فإن تحديد الصفة الأجنبية للحكم تتحدد بمكان صدوره وينبغي على ذلك أن الحكم الصادر في فرنسا أو إنجلترا يعد حكماً أجنبياً بالنسبة لمصر. وكذلك الحكم الصادر في إحدى الولايات الأمريكية يعد أجنبياً بالنسبة لباقي الولايات الأمريكية.

لكن يذهب الرأي الراجح في الفقه ← أن الحكم الأجنبي هو ذلك الحكم الصادر باسم سيادة دولة أجنبية بصرف النظر عن جنسية القضاة الذين أصدروا الحكم ودون إهتمام بالمكان الذي صدر فيه. وعلى ذلك يعد حكماً أجنبياً بالنسبة إلى مصر الحكم الصادر خارج مصر حتى ولو كانت المحكمة التي أصدرته يدخل في تشكيلها بعض القضاة المصريين، كما يعد حكم أجنبي وفقاً لهذا الرأي الحكم الصادر على أرض الدولة التي يتم تنفيذ الحكم فيها ما دام أن هذا الحكم صادراً باسم سيادة دولة أخرى أجنبية عن تلك الدول التي يراد تنفيذه فيها ويحدث ذلك في الفرض الذي تعترف فيه الدولة بولاية القضاء على إقليمها لقناصل الدول الأجنبية المعتمدين لديها .

الشرط الثاني : أن يكون الحكم الأجنبي صادراً في مواد القانون الخاص

يجب أن يكون الحكم الأجنبي الذي يُطلب تنفيذه في مصر صادراً في منازعة متعلقة بمسألة من مسائل القانون الخاص أي في مسألة مدنية أو تجارية أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أما الأحكام الأجنبية الصادرة في المواد الجنائية أو الإدارية أو المالية فإنها لا تكون واجبة النفاذ في مصر ويقتصر سلطان هذه الأحكام في حدود الدولة الصادرة عنها لتعلق الأمر بالنشاط السيادي للدولة وهو يتسم بالإقليمية.

العبرة في كون الحكم الأجنبي صادر في مسألة من مواد القانون الخاص أو كونه غير صادر فيها هي بطبيعة المسألة التي صدر فيها الحكم وليس بنوع المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وتحديد طبيعة هذه المسألة هي مسألة تكييف تخضع لقانون القاضي وفقاً لنص المادة ١٠ من القانون المدني المصري، وهو القانون المصري إذا كان الحكم يُراد تنفيذه في مصر.

واسناداً لما تقدم:

إن الحكم الصادر بالتعويض من محكمة أجنبية يعد قابلاً للتنفيذ في مصر حتى ولو كان صادراً من محكمة جنائية أو إدارية، ولا يقبل التنفيذ في مصر الحكم الصادر من محكمة مدنية أجنبية بتوقيع غرامة لأن العبرة بطبيعة المسألة وليس بنوع المحكمة التي أصدرت هذا الحكم. وقد نصت على ذلك صراحة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين مصر وفرنسا والموقعة في باريس بتاريخ ١٥ مارس ١٩٨٢

س ٥ : اكتب في الشروط الشكلية لتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر ؟

الشروط الشكلية المتطلب لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

الشرط الأول - الاختصاص القضائي الدولي بالمنازعة التي صدر فيها الحكم

نصت على هذا الشرط المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات بقولها "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

ظاهر هذا النص يفيد بأن ذلك الشرط له جانبين أحدهما سلبي ويتمثل في عدم دخول المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر في مجال الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية **والآخر إيجابي** ويتمثل في ثبوت الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم أو الأمر، **ومنطق هذا الترتيب** الذي نص عليه المشرع المصري في م ١/٢٩٨ حيث بدأ بالجانب السلبي ثم الجانب الإيجابي يقتضي أن تبدأ المحكمة المصرية التي يُطلب منها الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الصادر في بلد أجنبي بالبحث في قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون المرافعات المصري ليس لتحديد مدى اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم أو الأمر المراد تنفيذه وإنما لتبحث عما إذا كانت المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم أو الأمر تدخل في اختصاص المحاكم المصرية من عدمه بحيث إذا وجدت أنها تدخل في إحدى حالات اختصاص ولاية القضاء المصري رفضت الأمر بتنفيذ الحكم الجنائي دون حاجة لبحث الجانب الإيجابي أما إذا وجدت أن المنازعة لا تدخل في اختصاص ولاية القضاء المصري فإنها تبدأ في البحث عن مدى توافر الجانب الإيجابي وهو مدى ثبوت الاختصاص للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم فإذا رأت أن هذا الاختصاص بالمنازعة يثبت للمحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي فإنها تأمر بتنفيذه إذا توافرت الشروط الأخرى للتنفيذ، وإذا رأت أن هذا النزاع لا يدخل في اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم فإنها تمتنع وترفض الأمر بتنفيذه.

لكن يثار التساؤل عن القانون الواجب التطبيق أو الذي يتم الرجوع إليه لتحديد الاختصاص القضائي ومعرفة ما إذا كانت المحكمة الأجنبية مختصة بنظر المنازعة التي أصدرت فيها الحكم أو الأمر من عدمه ؟ أو بعبارة أخرى ما هو القانون الذي يتم الرجوع إليه لتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية؟

⚖️ **كان الاتجاه السائد في الفقه والقضاء قبل صدور قانون المرافعات** الملغي السابق الصادر عام ١٩٤٩ هو تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم الجنائي **بالرجوع لقانون القاضي** الذي يُطلب منه التنفيذ أي **القانون المصري** وهو ما كان سائد في قوانين بعض الدول الآخر مثل القانون الفرنسي والإيطالي والألماني والإنجليزي والأمريكي.

⚖️ **يستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه إلى عدة حجج:**

- ١- الرجوع لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون بلد المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم من شأنه الانتقاص والتوغل على قواعد اختصاص القضاء الدولي لمحاكم التنفيذ وذلك عندما تكون المنازعة التي صدر فيها الحكم الجنائي تدخل أيضاً في اختصاص محاكم الدولة التي يُطلب منها التنفيذ.
- ٢- تحديد الاختصاص القضائي الدولي وفقاً لقانون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم من شأنه تكليف للقاضي الوطني الذي يطلب منه التنفيذ أن يكون ملماً بقواعد الاختصاص القضائي في القوانين الأجنبية وهو ضرباً من المستحيل وفيه إرهاق للقاضي وتكلفه بما لا يطيق ولا يمكن تكليف الخصوم بمعاونته في هذا الخصوص حيث أنهم يلجأون عادة إلى إخفاء ما يملكونه من معلومات بشأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.
- ٣- يحاول أصحاب هذا الاتجاه التقريب بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي وقواعد تنازع القوانين فكلاهما قواعد مزدوجة الجانب قد تشير إلى تطبيق القانون الوطني أو المحكمة الوطنية أو تطبيق القانون الأجنبي أو المحكمة الأجنبية.

⚖️ **يذهب الفقه الراجح، الذي نميل إليه إلى نقد الاتجاه السابق وأنه لا يمكن التسليم به على أساس أنه:**

⚖️ **أولاً- الجانب السلبي** الذي قرره المادة ٢٩٨ مرافعات تكفل عدم الانتقاص والإفثات بالتوغل على قواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانون دولة القاضي الذي يطلب منه التنفيذ وهو القانون المصري حيث إذا وجد القاضي المصري أن المنازعة تدخل في اختصاص المحاكم المصرية فإنه يرفض الأمر بالتنفيذ ومن ثم كان على من صدر الحكم لصالحه أن يعود إلى رفع دعوى جديدة أمام القضاء المصري.

⚖️ **ثانياً- للقاضي أن يطلب مساعدة الخصوم في إثبات قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم** لأن من مصلحة الخصم الذي صدر الحكم الجنائي لصالحه أن ينفذه فلا شك إنه سيبذل جهده في مساعدة القضاء الذي يطلب إليه التنفيذ في سبيل تحقيق ذلك.

⚖️ **ثالثاً- أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تختلف عن قواعد تنازع القوانين** فإذا كانت هذه الأخيرة قواعد مزدوجة الجانب فإن قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد مفردة الجانب لا تحدد إلا اختصاص المحاكم الوطنية فقط ولا شأن لها بتحديد حالات الاختصاص بمحاكم الدول الأخرى لأن في ذلك اعتداء على سيادة تلك الدول.

⚖️ **لقد حسم المشرع المصري في قانون المرافعات الحالي هذا الخلاف بأن نص صراحة في المادة ٢٩٨ منه على الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون دولة المحكمة الأجنبية لمعرفة مدى اختصاصها بنظر المنازعة التي أصدرت فيها الحكم أو الأمر الذي يطلب من القاضي المصري تنفيذه.** ذلك لأن الحكم قد صدر في هذه الدولة فيكون من المنطقي تقدير صدوره من محكمة مختصة من عدمه وذلك من خلال الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في هذه الدولة وليس قانون الدولة التي يطلب التنفيذ فيها، كما أن هذا الحكم يتوافق مع نص المادة ٢٢ من القانون المدني المصري والتي تقرر "يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات".

⚖️ **نخلص مما تقدم** إلى أنه يُرجع في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لقانون دولة المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم أو الأمر الذي يُطلب تنفيذه أمام القضاء المصري فإذا كانت المحكمة الأجنبية مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في قانونها فإن المحكمة المصرية تأمر بتنفيذه إذا توافرت باقي شروط التنفيذ الأخرى.

⚖️ لكن يثار هنا تساؤل آخر مفاده هل يشترط أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة بنظر المنازعة التي أصدرت فيها الحكم أو الأمر الذي يطلب تنفيذه في مصر- وفقاً لقواعد الاختصاص الداخلي (النوعي والمحلي) المنصوص عليها في قانونها بالإضافة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي؟

⚖️ الواقع أن المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات لم تتناول سوى الاختصاص القضائي الدولي أما الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية فيذهب **الرأي الراجح** في الفقه إلى أنه لا يشترط توافر الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم لأن هذه المسألة إنما تخص القانون الأجنبي - وهو قانون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم وذلك ما لم تكن مخالفة قواعد الاختصاص الداخلي المقررة في هذا القانون تؤدي إلى بطلان الحكم إذ يتعين في هذه الحالة رفض الأمر بتنفيذه.

⚖️ **عن الوقت الذي يعتد فيه بتوافر الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية** إذا كانت مختصة بنظر النزاع فهو **وقت رفع الدعوى**، بينما الوقت الذي يتحدد فيه مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر فهو **وقت رفع دعوى طلب الأمر بالتنفيذ**.

⚖️ **أخيراً في حالة الاختصاص المشترك بين المحاكم المصرية والمحاكم الأجنبية بنظر النزاع**، فإذا كانت المحكمة الأجنبية مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانونها بنظر المنازعة، وكذلك كانت المحاكم المصرية مختصة هي الأخرى بنظر تلك المنازعة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري، **فهل يرفض القاضي المصري الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لمجرد كون القضاء المصري مختص بنظر تلك المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم وفقاً لقواعد الاختصاص المصرية؟**

⚖️ لاشك أن أعمال الجانب السلي المنصوص عليه في م ٢٩٨ من قانون المرافعات بشكل مطلق سيؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية في كل مرة ثبت فيها أن المحاكم المصرية تختص بنظر المنازعة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التضييق والتقليل من إمكانية تنفيذ الكثير من الأحكام الأجنبية حيث سيؤدي إلى تعطيل الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها في مصر مما يضر بالمعاملات الدولية خاصة وأن المشرع المصري قد أسهب في تفصيل حالات اختصاص المحاكم المصرية.

⚖️ **لهذا يكاد يجمع الفقه المصري على ضرورة تقييد هذا الجانب السلبي** الذي نص عليه المشرع في م ١/٢٩٨ من قانون المرافعات .

⚖️ يبدو أن المشرع قد شعر بالتعقيد الذي يمكن أن يثيره الشرط السلي المنصوص عليه صراحة في المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات فأشار في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون إلى أنه يفتح الباب في شأنه لاجتهاد الفقه والقضاء لمواجهة تطورات المعاملات الخاصة الدولية ومع ذلك فقد فات المشرع مبدأ تشريعاً صريحاً قد يقيد إلى حد كبير من قدرة الفقه والقضاء على مراعاة هذه المتطلبات وهو مبدأ أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.

⚖️ مع ذلك فقد حاول الفقه والقضاء التخفيف من التعقيد الوارد عن وجود هذا الشرط السلي تحت ستار الاجتهاد.

⚖️ **لقد أجمع الفقه في مصر على أن مجرد انعدام الاختصاص للمحاكم المصرية لا يكون في حد ذاته مبرراً لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي** غاية الأمر هو ضرورة تقييد الشرط أو الجانب السلي الوارد في نص المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات بحيث ترفض المحكمة المصرية الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي إذا توافر هذا القيد في اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي.

⚖️ **إذا كان الفقه قد اتفق على ضرورة توافر هذا القيد إلا أنه قد اختلف وانقسم إلى ثلاثة اتجاهات في تحديد هذا القيد ونتعرض لهذه الاتجاهات على النحو التالي:**

الاتجاه الأول: التقيد باعتباراً ملائمة:

⚖️ يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأصل هو أن الحكم الأجنبي الصادر في منازعة داخلية في اختصاص المحاكم المصرية لا يمكن تنفيذه في مصر ولكن استثناء من هذا الأصل فإنه يجوز تنفيذه فيها استناداً لاعتبارات الملائمة المبنية على العدالة وحاجة المعاملات الدولية لأنه من المتعذر وضع أسس علمية صرفة يتحدد بها هذا المجال.

🏛️ **تطبيقاً للقاعدة** التي يقترحها هذا الرأي فإن الحكم الأجنبي لا يمكن تنفيذه في مصر إذا كان داخلياً في اختصاص

المحاكم المصرية في الحالات الآتية:

- ١- تعلق النزاع بمال منقول أو عقار موجود في مصر لأنه أمر يهم سلامة المعاملات في مصر.
- ٢- حالات وقوع الفعل في مصر لأنه أمر يهم السكينة العامة (الأمن المدني).
- ٣- حالة الدعوى المتعلقة بإفلاس أشهر في مصر وذلك مراعاة لسلامة المعاملات.
- ٤- تعلق الدعوى بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للمصريين- لكفالة تطبيق القانون المصري في هذه المسائل على المصريين.

الحالات التي يجوز فيها إصدار الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي بواسطة القاضي المصري رغم دخول المنازعة في اختصاص المحاكم المصرية استجابة لاعتبارات الملائمة فتتمثل في:

١. حالة النزاع الناشئ عن عقد أبرم أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في مصر ما دام أن العقد لا يتعلق بمال موجود فيها تيسيراً للمعاملات الدولية ومراعاة لاعتبارات الملائمة.
 ٢. حالة الحكم الأجنبي الصادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب.
- 🏛️ **قد وجه النقد لهذا الرأي** على أساس قيامه على معيار غير منضبط من أجل تحديد الحالات التي يعترف فيها للقاضي المصري بتنفيذ الحكم الأجنبي رغم صدوره في منازعة داخلية في اختصاص المحاكم المصرية.

الاتجاه الثاني: النقيض بفكرة النظام العام القضائي:

🏛️ يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى **التفرقة في قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مصر بين تلك المتعلقة بالنظام العام**

والأخرى التي لا تتعلق بالنظام العام، بحيث إذا رأى القاضي المصري الذي يُطلب منه تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر دخول المنازعة التي فصل فيها الحكم الأجنبي في مجال اختصاص المحاكم المصرية بناء على قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية المتعلقة بالنظام العام فإنه يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي في هذا الفرض لأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي المتعلقة بالنظام العام يقصد منها حسن أداء العدالة وحماية السلام العام **ومن الأمثلة التي يضر بها صاحب هذا الرأي:**

🏛️ **(الدعوى المتعلقة بمال موجود في مصر- وكذلك المتعلقة بإفلاس أشهر فيها وأيضاً الإجراءات الوقائية والتحفظية التي تنفذ في مصر).**

🏛️ قواعد الاختصاص القضائي الدولي المصرية غير المتعلقة بالنظام العام والتي يقصد منها التيسير على المتقاضين فلا يوجد ما يمنع من قيام القاضي المصري بإصدار الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر رغم دخول المنازعة التي فصل فيها الحكم في اختصاص المحاكم المصرية بناء على قواعد الاختصاص القضائي الدولي غير المتعلقة بالنظام العام وهي تشمل حالات الاختصاص غير المذكورة في الحالة الأولى.

🏛️ **لكن ينتقد هذا الرأي** أيضاً على أساس قيامه على فكرة مجردة وغير منضبطة المعالم ولا يحسن الأخذ بها في مجال الاختصاص القضائي الدولي الذي يتعين فيه تبني ضوابط عملية وإقليمية.

الاتجاه الثالث: النقيض بقواعد الاختصاص القضائي الدولي القاصرة:

🏛️ **يفرق أصحاب هذا الاتجاه بين الاختصاص القاصر والاختصاص المشترك لحالات الاختصاص القضائي الدولي** أخذاً

بالتفرقة التي تبناها المشرع المصري في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات فذهب البعض إلى أن الاختصاص القاصر أو ما يرادفه من مصطلحات كالاختصاص المانع أو الاختصاص الضروري أو الاختصاص الإنفرادي، إنما يعني ثبوت الولاية لقضاء دولة واحدة على سبيل الاستثثار بحيث لا يشاركها ولاية قضاء دولة أخرى في نظر حالات هذا الاختصاص.

🏛️ **صاحب هذا الرأي قد قام بتحديد حالات الاختصاص القاصر في ثلاثة حالات تتمثل في:**

- ١- حالة تعلق النزاع بحق عيني يراد تقريره على عقار كائن في مصر أو نفيه عنه.
- ٢- حالة تعلق النزاع بإجراء وقفي أو بتنفيذ جبري يتعين اتخاذه أو إجراءه في مصر.
- ٣- حالة اتفاق الأطراف على عقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء المصري (الخضوع الاختياري).

⚖️ **غير أنها هناك جانب آخر من الفقه نميل إليه** ← يرى أن معيار التفرقة بين الاختصاص المانع أو القاصر والذي يرفض معه القاضي المصري تنفيذ الحكم الأجنبي لدخول المنازعة في نطاق هذا الاختصاص القاصر للمحاكم المصرية والتي لا يشاركها فيه اختصاص محاكم دول أخرى يتمثل في **الصلة الوثيقة بين المنازعة وولاية القضاء المصري بنظرها**، فإذا كانت المنازعة تتصل بصلة وثيقة بولاية المحاكم المصرية يتعين إنعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء المصري فإذا فصلت في هذه المنازعة محكمة دولة أجنبية فإن القاضي المصري يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر في هذه الحالة، **لذلك فإنه استناداً لاعتبارات النفاذ والفعالية يحسن أن يترك أمر الفصل فيها للقضاء المصري وحده باعتباره الأجدر على النظر والفصل في هذه المنازعة عن غيره من محاكم الدول الأخرى** أما إذا كانت المنازعة لا ترتبط بصلة وثيقة بولاية القضاء المصري وإنما ترتبط هذه الصلة بولاية المحكمة الأجنبية التي أصدرته فلا يوجد ما يمنع القاضي المصري من إصدار الأمر بتنفيذ ذلك الحكم باعتبار أن نظر هذه المنازعة يدخل في حالات الاختصاص المشترك بين القضاء المصري وقضاء البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم.

⚖️ **أساس تفضيلنا لهذا الاتجاه** ← يرجع إلى كونه هو الذي أخذت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات الحالي الأمر الذي يعني أن هذه الفكرة كانت قائمة في ذهن المشرع وهو بصدد وضع قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية وقصد ألا يعالجها بنصوص تشريعية مفضلاً تركها لاجتهاد الفقه والقضاء ليواجهان بها تطور المعاملات الدولية الخاصة كما يرجع تفضيلنا للرأي الثاني الذي يقيم معيار لهذه التفرقة مستمداً من مدى الصلة الوثيقة بين المنازعة وولاية القضاء المصري على أساس كونه معيار نسي ويتسم بالمرونة يسمح للقاضي الذي يُطلب منه تنفيذ الحكم الأجنبي بفحص كل حالة على حدة دون تقييده بحالات معينة على سبيل الحصر.

موقف القضاء المصري من هذه الاتجاهات:

⚖️ أخذ القضاء المصري في تحديده للحالات التي يختص فيها بالمنازعة دون غيره بفكرة الاختصاص **القاصر والاختصاص المشترك** من ذلك نذكر حكم محكمة النقض المصرية الذي قضى بأن "المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية.

أحكام المحكمين الأجنبية:

⚖️ **يثار التساؤل هل تطبق أحكام المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات المصري على أحكام المحكمين الأجنبية؟** خاصة وأن المادة ٢٩٩ من قانون المرافعات تنص على أنه "تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

⚖️ **فيما يتعلق بالجانب الإيجابي** الذي نصت عليه المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات المتعلق بثبوت الاختصاص فإنه يتعين توافره أيضاً في أن أحكام المحكمين فيشترط أن تكون هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم مختصة بالمنازعة التي أصدرت حكمها فيها وهي تكون مختصة استناداً لوجود اتفاق التحكيم - شرط أو مشاركة تحكيم - حيث أن المحكمين يستمدون سلطتهم في الفصل في النزاع المطروح أمامهم من هذا الاتفاق والذي لولاه لما اختصت هيئة التحكيم بنظر النزاع ولدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء الوطني باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات.

🏛️ **الجانب السلبي** لنص المادة ١/٢٩٨ من قانون المرافعات المتعلق بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم فلا يشترط وجوده حيث لا يتصور الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمون بحجة أن الفصل في المنازعة يدخل في اختصاص ولاية القضاء المصري بل أن مجرد وجود اتفاق التحكيم يعد في حد ذاته سبباً لامتناع القضاء الوطني من نظر المنازعة لوجود اتفاق التحكيم. فهذا الاتفاق هو الذي ينزع الاختصاص من القضاء الوطني ويعهد به إلى المحكمين فهو دستور العملية التحكيمية. ونصت على ذلك المادة ١٠ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والتي تقرر بأنه "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية".

🏛️ ورغم ذلك فإن يشترط في حكم التحكيم حتى يمكن تنفيذه أن يكون صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم قد نص المشرع في المادة ١١ من قانون التحكيم المصري على أنه "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح". وبالتالي فإن المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقاً لنص المادة ٢٩٩ من قانون المرافعات هي المسائل التي يجوز فيها الصلح وهي تلك التي لا تتعلق بالنظام العام.

الشرط الثاني - صحة تكليف الخصوم بالحضور وصحة تمثيلهم في الخصومة

🏛️ نصت على هذا الشرط صراحة م ٢/٢٩٨ من قانون المرافعات المصري بقولها: لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

🏛️ أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

🏛️ **صياغة هذا الشرط على النحو المتقدم لا يعبر في حقيقة الأمر عن الهدف منه** والذي يتمثل في سلامة وصحة الإجراءات القضائية التي اتبعت في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي والذي يراد تنفيذه على الإقليم المصري ولذلك فإن غالبية الفقه تُعبر عن هذا الشرط بصحة الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم أو الأمر الأجنبي حيث أنه من المتصور أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً لكن كان هناك إخلال بباقي الإجراءات الأساسية في التقاضي كالإخلال بحقوق الدفاع لذلك يجب أنه يُفهم هذا الشرط على أنه **يتطلب ضرورة مراعاة الحكم الأجنبي للإجراءات الأساسية في التقاضي والتي بوشرت في الدعوى التي صدر فيها.**

🏛️ كما نصت على ضرورة مراعاة هذا الشرط الفقرة (ب) من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول جامعة الدول العربية والتي انضمت إليها مصر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤م، والتي تقرر "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية: ب- إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .

🏛️ **لهذا يرى بعض الفقه أن الغاية من استلزام هذا الشرط هو الإطمئنان من أن الخصم الذي صدر ضده الحكم قد مُكن من إبداء دفاعه في الدعوى، والمرجع في تحديد مدى سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى هو قانون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم وليس إلى قانون القاضي الذي يطلب منه التنفيذ باعتبارها مسألة إجراءات تخضع لقانون المحكمة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات وفقاً لنص المادة ٢٢ من القانون المدني المصري التي تقضي بأنه "يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات".**

🏛️ **يترتب على ذلك** أن قانون الدولة التي أقيمت فيها الدعوى وصدر فيها الحكم الأجنبي الذي يُراد تنفيذه على الإقليم المصري هو الذي يحدد ما إذا كان المدعى عليه قد تم إعلانه على الوجه الصحيح، وأنه قد روعيت في الدعوى الإجراءات الأساسية في التقاضي دون إخلال بحقوق الدفاع وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وفقاً لهذا القانون باعتباره القانون الذي يحكم كافة مسائل الإجراءات.

إذا تبين للقاضي المصري الذي يُطلب منه التنفيذ أنه قد تم مخالفة أحكام القانون الذي يحكم الإجراءات في البلد الأجنبي أو أن الخصوم لم تكلف بالحضور أو لم تمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بأن كان المدعى عليه قاضراً ولم يمثله من له الولاية أو الوصاية عليه أو لم يتم إعلانه إعلان صحيحاً بالحضور أو لم تتاح له مُكنة الدفاع عن نفسه أو رفضت المحكمة الأجنبية إطلاعه على المستندات المقدمة في الدعوى للرد على خصمه، فإن القاضي المصري يرفض تنفيذ الحكم الأجنبي الذي لم يراعى هذه الإجراءات وفقاً لقانون المحكمة التي أصدرته هذا بالنسبة للحكم الأجنبي الحضور أما فيما يتعلق بالحكم الغيابي فليس هناك ما يمنع من الأمر بتنفيذه ما دام ثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً .

قد انتقد جانب من الفقه، هذا الشرط على أساس أنه من النادر أن يدفع أحد الخصوم بعدم صحة الإجراءات القضائية التي صدر على أثرها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه على الإقليم المصري لأنه من ضمن الشروط الأخرى المطلوبة في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه هو حيازته لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون الدولة التي أصدرته ومن ثم فليس هناك مبرر لاشتراط صحة الإجراءات المتبعة عند إصدار كشرط مستقل لأن الحجية التي يتمتع بها هذا الحكم تمنع بطلانه.

كما أنه من غير الملازم أن يحل القاضي الوطني الذي يطلب منه التنفيذ محل المحكمة العليا في الدولة الأجنبية التي أصدرت محاكمها الحكم ليراقب مدى صحة تطبيق هذه المحاكم للإجراءات القضائية في الدعوى التي أصدرت فيها المحكمة للحكم الأجنبي إذ أن القاضي الذي يُطلب منه التنفيذ لن يكون أكثر فهماً وإلماماً بقانون الإجراءات المدنية الأجنبي من قضاة المحكمة الأجنبية نفسها ولكن أياً ما كان من أمر هذا النقد فقد استلزمه المشرع المصري بالنص الصريح عليه في المادة ٢/٢٩٨ من قانون المرافعات المصري.

الشرط الثالث - حيازة الحكم الأجنبي لقوة الأمر المقضي به

نص قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ٣- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته".

يستفاد من هذا النص أنه يلزم في الحكم الأجنبي حتى يمكن الاعتراف به وتنفيذه على الإقليم المصري أن يكون هذا الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به وهو يكون كذلك إذا كان الحكم النهائي لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) وإن أمكن الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية (النقض والتماس إعادة النظر).

بناءً على ذلك فإنه يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي وكذلك البات باعتبار أن الحكم البات هو الذي استنفذ طرق الطعن عليه العادية وغير العادية.

الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به على الوجه المختلف عن الحكم الحائز لحجية الأمر المقضي به ← فهذه الأحكام الأخيرة إنما تثبت للأحكام القطعية أي تلك التي تفصل في موضوع النزاع حتى ولو لم تكن أحكام نهائية قابلة للطعن فيها سواء بالطرق العادية أو غير العادية فالحكم القطعي يعد حجة فيما فصل فيه يحوز تلك الحجية ويعتبر عنوان الحقيقة حتى ولو كان مخالفاً لها فلا يجوز المساس بما قضى به الحكم بين الخصوم ولا يجوز إعادة طرح موضوع النزاع مرة أخرى بين ذات الخصوم ولذات الأسباب للفصل فيه من جديد وإن أمكن الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى درجة في الأحوال والأوضاع التي يجوز فيها ذلك وعلى ذلك فإن الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي به أوسع نطاقاً من الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي به حيث يمكن القول بأن كل حكم حائز لقوة الأمر المقضي به يكون حائز لحجية الأمر المقضي به دون العكس.

يثار التساؤل عن أي الأحكام الأجنبية التي تقبل التنفيذ على الإقليم المصري الحائزة لقوة الأمر المقضي أم تلك التي تمتنع بحجية الأمر المقضي؟

بالرجوع لنص المادة ٢/٢٩٨ من قانون المرافعات نجد أن المشرع المصري قد اشترط أن يكون الحكم الأجنبي المراد تنفيذه حائز لقوة الأمر المقضي به أي أن يكون حكم نهائي لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية ويمتاز موقف المشرع المصري في ذلك أنه حريصاً على كفالة الاستقرار اللازم للمعاملات وتوفير الأمان القانوني حتى لا يفاجئ الأطراف بأن الحكم الأجنبي الذي تم تنفيذه قدم الطعن عليه وإلغائه في البلد الأجنبي الذي تتبعه المحكمة التي أصدرته.

كما أن المشرع المصري يتطلب لتنفيذ الأحكام المصرية أن تكون حائزة لقوة الأمر المقضي، فمن باب أولى يجب تمتع الأحكام الأجنبية هي الأخرى بهذه القوة حتى لا تتميز على الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية عند الأمر بتنفيذها.

يثار التساؤل عن القانون الذي يتم الرجوع إليه لتحديد حيالة الحكم لقوة الأمر المقضي به هل هو قانون القاضي الذي يُطلب منه التنفيذ أي القانون المصري - على النحو الذي بيناه أم وفقاً لقانون المحكمة الأجنبية التي أصدرته؟

حسم المشرع المصري هذا الأمر وذلك بالنص الصريح في المادة ٢/٢٩٨ على أن المرجع في اعتبار الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به من عدمه هو **بالرجوع لقانون الدولة التي صدر عن محاكمها**، وهو ما يتوافق مع نص المادة ٢٢ من القانون المدني المصري الذي يستلزم الرجوع لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات لحكم كافة المسائل الخاصة بالإجراءات ومن ثم يستتبع الرجوع لهذا القانون لبيان مدى حيالة الحكم لقوة الأمر المقضي به من عدمه.

رأينا الخاص:

ترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية على الإقليم المصري إذا كانت:

- أحكام قطعية حائزة لحجية الأمر المقضي ما دامت لم تحوز قوة الأمر المقضي به أي لم تعد نهائية.
 - لا تجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية المشمولة بالنفذ المعجل.
 - كما لا تجوز تنفيذ الأحكام الوقتية والتحفظية لأنها قائمة على صفة الاحتمال كما أن الاختصاص بها يقتصر على المحاكم المصرية وحدها باعتبارها من الاختصاص القاصر على المحاكم المصرية وحدها وفقاً لنص المادة ٣٤ من قانون المرافعات.
- الأحكام الأجنبية التي يجوز الأمر بتنفيذها على الإقليم المصري هي الأحكام النهائية والباتة الحائزة لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون المحكمة الأجنبية التي أصدرتها.

فيما يتعلق بالأعمال الولائية - الأوامر الأجنبية التي يُطلب تنفيذها على الإقليم المصري فظاهر نص المادة ٣/٢٩٨ يتطلب ضرورة تمتع هذه الأعمال بقوة الأمر المقضي به في حين أن هذه الأوامر تصدر غير حائزة لحجية الأمر المقضي به أصلاً ولعل الوسيلة الوحيدة لدفع هذا التعارض الذي قد يوحي به النص هو تفهم هذا الشرط على معنى "أن الأمر قد انتهى ميعاد التظلم منه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره إذا كان هذا القانون يجيز التظلم ويحدد له ميعاد".

الشرط الرابع - عدم مخالفة الحكم أو الأمر لنصوص الدستور المصري

تمت إضافة هذا الشرط صراحة في المادة ٢٧ مكرراً من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م، المضافة بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢١م والتي تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة."؛ وعلى ذلك فإنه يشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية التي تصدر في مواجهة الدولة أن تكون دستورية وتتفق مع أحكام الدستور المصري، بحيث تمتنع المحكمة المصرية عن إصدار الأمر بتنفيذها إذا تضمنت ما يخالف أحكام الدستور المصري. وفي هذه الحالة يتقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة. وتفصل المحكمة الدستورية في شأن مدى دستورية هذا القرار أو الحكم على وجه السرعة.

الشرط الخامس - عدم تعارض الحكم أو الأمر الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية

نص قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية".

يستفاد من هذا النص أن سبق نظر المنازعة والفصل فيها بواسطة إحدى المحاكم المصرية ثم صدور حكم من محكمة دولة أجنبية في ذات المنازعة وبين نفس الخصوم ويراد تنفيذ هذا الحكم في مصر فلا شك أنه يمتنع على القاضي المصري أن يصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لسبق صدور حكم من المحاكم المصرية في ذات المنازعة التي فصل فيها الحكم الأجنبي خاصة فيما لو تعارض هذان الحكمين فيما قضيا به لتعلق الأمر باعتبارات السيادة الوطنية للدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم الأجنبي، فليس من المعقول أن يهدر القاضي الوطني حجية وقيمة الحكم الصادر من محاكم دولته ويقوم بتفضيل تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دولة أجنبية على الحكم الوطني.

يرى بعض الفقه أنه في الحالة التي يتعارض فيها الحكمان فيما يقضيان به فإن تفضيل الحكم الأجنبي على الحكم المصري إنما يعني أن القضاء الأجنبي أقدر على أداء العدالة من القضاء المصري الأمر الذي يزرى من هذا الأخير ويحط من قدره.

التساؤل الذي يثار هنا هو هل يشترط في الحكم المصري أن يتماثل في قوة الأمر المقضي به مع الحكم الأجنبي الذي يتعارض معه؟

يذهب بعض الفقه ← إلى اشتراط مثل هذا التماثل بين الحكمين حتى يمكن رفض تنفيذ الحكم الأجنبي أما في الحالة التي لم يحوز فيها الحكم المصري لقوة الأمر المقضي به فإن الحكم الأجنبي يعد أشد تأكيد للحق الذي يقرره في هذه الحالة من الحكم المصري الأمر الذي يفضل معه الحكم الأجنبي عن الحكم الوطني.

لكن يذهب الرأي الراجح في الفقه المصري ← على أن مجرد سبق صدور حكم قطعي من أحد المحاكم المصرية ولو لم يكن حائزاً لقوة الأمر المقضي به يكفي في حد ذاته لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض معه وذلك لصراحة النص حيث اكتفي بالقول بأن ما يمنع من تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر هو مجرد سبق صدور حكم من القضاء المصري يتعارض معه إذ لو أراد المشرع اشتراط التماثل في القوة بين الحكمين لذكر ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لاشتراطه حيازة الحكم الأجنبي لقوة الأمر المقضي به .

إذا كان وجود حكم قضائي مصري سابق يتعارض مع الحكم الأجنبي سبباً لرفض تنفيذ هذا الحكم الأخير على الإقليم المصري **فهل مجرد وجود دعوى قائمة أمام القضاء المصري تتعلق بذات المنازعة التي فصل فيها الحكم الأجنبي وبين ذات الخصوم سبب لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي رغم عدم صدور حكم في هذه الدعوى؟**

ذهب بعض الفقه ← أن مجرد وجود هذه الدعوى يعد في حد ذاته سبب لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي حتى لو كانت هذه الدعوى قد أقيمت بعد صدور الحكم الأجنبي.

قد انتقد الفقه المصري الراجح هذا الرأي ← على أساس أن هذا الرأي يتعارض مع صريح نص المادة ١٤/٢٩٨ من قانون المرافعات والتي لا تنص على رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كان هناك حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية وليس مجرد دعوى منظورة لم يصدر فيه حكم، بل حتى ولو صدر هذا الحكم بعد صدور الحكم الأجنبي. على أساس أنه يشترط سبق صدور حكم المحكمة المصرية أولاً حتى يتم رفض تنفيذ الحكم الأجنبي أما أنه وقد صدر الحكم المصري بعد صدور الحكم الأجنبي أو كانت هناك دعوى منظورة ولم يفصل فيها بخصوص ذات النزاع وبين نفس الخصوم فإنه ليس سبباً لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي، والقول بغير ذلك إنما يفتح الباب للغش والتحايل على القانون، وذلك بقيام الخصم سيء النية (المحكوم ضده) بإقامة دعوى أمام المحاكم المصرية بمجرد صدور حكم المحكمة الأجنبية ضده حتى يتم رفض تنفيذ الحكم الأجنبي على الإقليم المصري الأمر الذي يضر بمصالح الأفراد.

يثار تساؤل أخير عن الحل الواجب الاتباع في حالة صدور حكمين أجنيين متعارضين ويراد تنفيذهما في مصر فاي منهما يجب تنفيذه؟

ذهب بعض الفقه ← أن العبرة هي بتاريخ صدور الحكم بحيث يتم تنفيذ الحكم الأجنبي الذي صدر أولاً متى استوفى باقي شروط التنفيذ.

في حين يذهب البعض الآخر ← أنه يفضل تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في دولة القاضي الذي يطلب منه الأمر بالتنفيذ.

بينما نذهب مع الرأي الراجح في الفقه ← إلى أن العبرة هي تفضيل تنفيذ الحكم الأجنبي الأسبق في تاريخ تقديم طلب تنفيذه للمحاكم المصرية وليس الأسبق في تاريخ صدوره بحيث إذا تقدم طلب بتنفيذ أحد الحكمين المتعارضين وليكن الحكم اللاحق في تاريخ صدوره عن الأول والذي لم يقدم طلب بتنفيذه فإن صدور أمر القاضي المصري بتنفيذ هذا الحكم يمنع من تنفيذ الحكم الأجنبي الآخر لسبق تنفيذ الحكم الأجنبي الذي تم تقديم طلب تنفيذه أولاً.

س٦١ / يشترط لتنفيذ الحكم أو الامر الاجنبي في مصر عدم التعارض مع النظام العام . وضع ذلك؟

الشرط السادس- عدم تعارض الحكم أو الأمر الأجنبي مع النظام العام في مصر

نصت على هذا الشرط المادة ٤/٢٩٨ من قانون المرافعات بقولها "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".

يعد هذا الشرط من الشروط المعتاد النص عليها في قوانين الدول المختلفة بل ويجري القضاء على العمل به، حتى في حالة عدم وجود نص صريح به ووفقاً لهذا الشرط فإنه ينبغي رفض تنفيذ الحكم الأجنبي الذي يبدو متعارضاً مع الأسس الجوهرية السائدة في دولة القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.

تطبيقاً لذلك ← يعتبر الحكم الأجنبي مخالفاً للنظام العام المصري (مما يتعين عدم الاعتداد به ورفض تنفيذه) الحكم الأجنبي الصادر ضد زوجة مسلمة بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها غير المسلم المرتد عن الإسلام، وكذلك الحكم الصادر ضد أحد المصريين بخصوص عقد دولي يلزمه فيه بالوفاء بقيمة التزاماته على أساس الدفع بالذهب.

الواقع أنه إذا كان يتم استخدام فكرة النظام العام في ظل منهجية تنازع القوانين بهدف استبعاد القاضي الوطني المطروح أمامه النزاع للقانون الأجنبي الذي أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاصه وإحلال القانون الوطني للقاضي بدلاً منه فإنه يتم استخدام نفس الفكرة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية ولكن في أثرها السلبي دون الإيجابي بمعنى أن القاضي الوطني يرفض الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي الذي يكون متعارضاً مع المبادئ الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والروحية التي يقوم عليها مجتمع دولته دون إحلال أي حكم آخر محل هذا الحكم.

لتقدير مدى مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام في مصر لا ينبغي قصر النظر على منطوق الحكم فقط وإنما ينظر للحكم الأجنبي في مجموعه بما اشتمل عليه من حيثيات وأسباب خاصة وأن المنطوق في بعض الأحكام لا يتضح إلا بالرجوع إلى الأسباب.

ينثار التساؤل عن حكم الحالة التي يخلو فيها الحكم الأجنبي من الأسباب خاصة وأن القانون المصري يوجب تسبيب الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية ويرتب البطلان في حالة خلوها وفقاً لنص المادة ١٧٦ من قانون المرافعات المصري فهل ينطبق نفس الشرط على الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر؟

قد قضت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ٦ مايو ١٩٦٩ بالإجابة على هذا التساؤل بأنه "المادة ٢٢ من القانون المدني إذ نصت على أنه يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات". فقد أفادت خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى، وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرة هي الأخرى الإقليمية. لما كان ذلك وكانت قاعدة وجوب اشتغال الحكم على الأسباب التي بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي وهو قانون جمهورية السودان في الحكم المطلوب تنفيذه في الدعوى الحالية، وكان يبين من ذلك الحكم أنه وإن لم يشتمل على أسباب إلا أنه - وعلى ما جاء بالشهادة المؤرخة ١٩٦٢/١٢/١٥ المرفقة به - قابل للتنفيذ في جمهورية السودان وبالتالي يمكن إصدار الأمر بتنفيذه في مصر إذا استوفت باقي الشرائط الأخرى المقررة في هذا الخصوص، وكان لا يقدر في ذلك ما قضت به المادة ٣٤٧ من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتغال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التي تصدر في مصر، طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة. لما كان ما تقدم فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب يكون على غير أساس".

تميل أحكام القضاء الفرنسي ← إلى الأخذ بفكرة الأثر المخفف للنظام العام في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية الذي تتسم به أيضاً في مجال تنازع القوانين وذلك في المسألة التي لا تتعلق بإنشاء حق في دولة القاضي المطلوب منه التنفيذ وإنما مجرد الاعتراف بآثار حق قد ثبت وتم اكتسابه في الخارج.

تطبيقاً لهذه الفكرة ← فإن القضاء الفرنسي يعترف بحكم الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة في مصر وكذلك بالزواج الثاني الذي يتم بين مسلمين في مصر على الرغم من عدم إمكانية إنشاء هذين الحقين ابتداء في فرنسا لمخالفته للنظام العام الفرنسي.

أخيراً فإن الوقت الذي يعتد فيه بمخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام في مصر هو **الوقت الذي يطلب فيه التنفيذ من القاضي المصري** لا وقت صدور الحكم من المحكمة الأجنبية.

الشرط السابع - المعاملة بالمثل (التبادل)

يقصد بالمعاملة بالمثل أو التبادل في تنفيذ الأحكام الأجنبية ← "معاملة الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر". وبذلك تكون للأحكام الأجنبية التي يراد تنفيذها في مصر ذات القيمة التي تُعطي للأحكام المصرية في الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم الأجنبي.

قد نصت على هذا الشرط المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات بقولها "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه".

حددت محكمة النقض المصرية المقصود بشرط المعاملة بالمثل حيث قضت بأن "المقصود بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول هو التبادل التشريعي المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها الإقليمية، فإن ثبت هذا التبادل التشريعي فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على مدعاه".

على ذلك فإن القاضي المصري يعترف ويأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بنفس الشروط التي يقررها قانون الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه على الإقليم المصري.

لايضاح ذلك نبين الأنظمة السائدة بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية

أولاً: نظام المراجعة (الدعوى الجديدة):

في ظل نظام المراجعة يقوم القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي بمراجعة هذا الحكم من حيث الواقع والقانون حتى يتأكد من أن القاضي الأجنبي لم يرتكب ظهماً صارخاً وأنه طبق قانونه تطبيقاً سليماً على موضوع النزاع بحيث إذا تبين له خطأ هذا الأخير في الحكم في النزاع امتنع عن إصدار الأمر بتنفيذه.

يتعين على من يرغب في تنفيذ حكمه رفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني ويقدم الحكم الأجنبي باعتباره دليل فيها على ثبوت حقه وتكون المشكلة أمام القاضي حول قيمة هذا الدليل هل يعد دليل قطعي لا يقبل إثبات العكس أم دليل نسبي يقبل إثبات العكس، ويتم حل هذه المشكلة في ضوء مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للحكم الأجنبي نفس القيمة التي تعطيها المحاكم الأجنبية للحكم الوطني إذا أراد أن ينفذ في دولة المحكمة الأجنبية والتي يراد تنفيذ حكمها في الدولة الوطنية.

في ظل نظام المراجعة يمكن لقاضي التنفيذ قبول طلبات جديدة لم يتم تقديمها أمام محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه أو اختصاص الغير الذي لم يختصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي كما أن قاضي التنفيذ لا يتقيد بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم الأجنبي فلا توجد حجية لهذا الحكم الأخير أمام القاضي الوطني، فهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الوقائع وتطبيق القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد في قانونه الوطني والذي قد يختلف تبعاً لذلك عن القانون الذي طبقت به المحكمة الأجنبية الأمر الذي يتصور معه انتهاء قاضي التنفيذ لنتيجة مخالفة لما قرره الحكم الأجنبي السابق الذي كان يبتغي تنفيذه على الإقليم الوطني لذلك فإن علاقة محكمة دولة التنفيذ بمحكمة الدولة التي أصدرت الحكم الأجنبي تشبه علاقة محكمة الاستئناف بمحكمة الموضوع فكان محكمة دولة التنفيذ هي هيئة استئنافية لمحكمة الدولة الأجنبي التي أصدرت الحكم الأجنبي.

يترتب على ما تقدم ← إنه إذا عرض على القاضي المصري حكم أجنبي يراد تنفيذه في مصر فإنه وفقاً لشرط المعاملة بالمثل إذا تبين للقاضي المصري أن محاكم الدولة الأجنبية التي أصدرت الحكم تأخذ بنظام المراجعة لتنفيذ الأحكام المصرية فيها ففي هذه الحالة يمكن للقاضي المصري أن يقوم بمراجعة الحكم الأجنبي من حيث الواقع والقانون كما يفعل القاضي الأجنبي بالنسبة لتنفيذ الحاكم المصرية في هذا البلد الأجنبي، وعلى ذلك يمكن رفع دعوى جديدة أمام القضاء المصري دون التقيد بقواعد الاختصاص القضائي الدولي في هذا الفرض، ويمكن بالتالي للقاضي المصري قبول طلبات جديدة أو اختصاص الغير ويمكن أن يقرر الحق لمن صدر الحكم الأجنبي السابق ضده، كما له أن يقوم بتطبيق قانون آخر غير القانون الذي طبقت به المحكمة الأجنبية للفصل في موضوع النزاع.

ثانياً: نظام المراقبة

في ظل هذا النظام يقوم **المشرع بوضع حد أدنى من الشروط التي يتعين توافرها لإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية**، بحيث لا يتم تنفيذ هذه الأحكام بواسطة القاضي الوطني إلا بعد مراقبة مدى تحقق هذه الشروط دون مراقبة الحكم الأجنبي نفسه من حيث الواقع أو القانون كما لا يجوز له قبول طلبات جديدة أو اختصام الغير على النحو الذي يعمل به في ظل نظام المراجعة إنما يراقب الشروط التي تطلبها المشرع لإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإذا وجدها متحققة اعترف بالحكم الأجنبي وأمر بتنفيذه وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه يرفض الاعتراف بالحكم الأجنبي ويمتنع عن إصدار الأمر بتنفيذه.

يثار التساؤل عن الحالة التي يأخذ فيها قانون قاضي التنفيذ بنظام المراقبة وقانون بلد المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه على الإقليم الوطني بنظام المراقبة هو الآخر، وقد تضمن قانون كلا منهما شروط تمثل حد أدنى لتنفيذ الأحكام الأجنبية فبأي شروط يعتد بها قاضي التنفيذ عند مراقبة الحكم الأجنبي هل يأخذ بالشروط المنصوص عليها في قانون البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المطلوب تنفيذه أم يأخذ بالشروط المنصوص عليها في قانونه الوطني؟

نص المشرع المصري في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات على أنه "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه" الأمر الذي يفهم منه أن الحكم الأجنبي ينفذ في مصر بنفس الشروط التي ينص عليها المشرع الأجنبي لتنفيذ الأحكام المصرية على إقليمه. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه "النص في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات". يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقي، ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها.

على هذا الأساس فإن قيمة الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات تظهر من خلال التفرقة بين الفروض الآتية:

- **الفرض الأول** - إذا كان قانون البلد الأجنبي يعترف ويقوم بتنفيذ الأحكام الأجنبية لديه - ومنها الأحكام المصرية - دون تطلب توافر أية شروط لإمكانية تنفيذها فإن الأحكام الصادرة من محاكم هذا البلد الأجنبي يمكن تنفيذها في مصر إذا تحقق القاضي المصري من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات المصري باعتبارها شروط لا غنى عنها لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.
- **الفرض الثاني** - إذا كان قانون البلد الأجنبي يقرر شروط أقل شدة من تلك التي يقرها القانون المصري وفي هذه الحالة أيضاً يقوم القاضي المصري بالتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات.
- **الفرض الثالث** - إذا كان قانون البلد الأجنبي يقرر لإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية على إقليمه - ومنها الأحكام المصرية - شروط أكثر شدة من تلك التي يقرها القانون المصري، وفي هذا الفرض فإن القاضي المصري يتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات بالإضافة إلى الشروط الأخرى الأكثر شدة التي تطلبها المشرع الأجنبي لتنفيذ الأحكام المصرية فيه وفقاً لنص المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات المصري.

وبذلك يتضح لنا أن المشرع المصري يأخذ بنظام المراقبة مصحوباً بنظام المعاملة بالمثل.

الشرط الثامن - عدم وجود إتفاقية دولية تنظم مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية بالدولة

تنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات المصري على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن"، يتبين من ذلك أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول أو تلك التي تنضم إليها، تعد بعد نفاذها بمثابة القانون الواجب التطبيق الذي يتعين إعمال قواعده في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من إحدى الدول الطرف في الاتفاقية حتى ولو تعارضت أحكامها مع أحكام القانون الداخلي للدولة التي يطلب إليها التنفيذ.

الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية تلزم الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة، وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية، وحيث أن مصر قد وافقت على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤م ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ ١٩٥٤/٧/٢٥م. ومن ثم تعد هذه الاتفاقية هي القانون الواجب التطبيق بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في أي دولة من الدول التي وافقت عليها. وقد نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى.

لا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:

١. إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها (عدم الاختصاص المطلق) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي.
 ٢. إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.
 ٣. إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، هي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
 ٤. إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
- تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية بشأن مصر وغيرها من الدول مثل اليمن والإمارات والبحرين والكويت وفرنسا.

س ١٧: وضع إجراءات دعوى تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر؟

إجراءات دعوى تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

أولاً: تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية:

فرق المشرع المصري بين وسيلة تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ووسيلة تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية ← فجعل وسيلة تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية عن طريق دعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى (صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصوم). على ذلك فإن الجهة المختصة بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هي المحكمة الابتدائية وليس قاضي التنفيذ ما لم تنص اتفاقية تنفيذ الأحكام المنضمة إليها الدولة على غير ذلك. على عكس ذلك فإن وسيلة تنفيذ السندات الرسمية الأجنبية يتم عن طريق عريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه.

ثانياً: تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب:

يستند المحكمين سلطتهم في الفصل في النزاع المطروح أمامهم من اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف والذي لولاه لما اختصت هيئة التحكيم بنظر النزاع ولدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات. وقد عرفت المادة ١٠ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م، اتفاق التحكيم بأنه:

- ١- اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
- ٢- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ... كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وألا كان الاتفاق باطلاً.

٣- يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من هذا العقد، كما قضى في ذلك بأن "اتفاق التحكيم المعقود بين الطرفين (شرطاً كان أو مشارطة) هو دستور التحكيم ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع وهو الذي ينتزع الخصومة من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات. وذهب بعض الفقه في تحديد طبيعة نظام التحكيم بأن التحكيم في أوله اتفاق وأوسطه إجراء وآخره حكم.

٤- **تحوز أحكام المحكمين، شأن أحكام القضاء، حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها** وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

⚖ **يتم تنفيذ أحكام المحكمين استناداً لقانون التحكيم المصري** ← وفقاً لنصوص المواد (٩، ٥٦، ٥٨) منه، وقد حددت المادة الأولى من هذا القانون نطاق تطبيقه، فقصرت تطبيق أحكامه على كل تحكيم يجري في مصر أياً كان نوعه أو إذا كان تحكيمياً تجارياً دولياً يجري في الخارج، فيشترط أن يتفق أطرافه على الخضوع لأحكامه.

⚖ **بالنسبة لأحكام المحكمين الأجنبية غير الخاضعة لأحكام قانون التحكيم المصري** ← والتي تصدر في الخارج ولم يتفق أطراف التحكيم فيها على الخضوع للقانون المصري ويطلب تنفيذها في مصر، فإنها تخرج عن نطاق تطبيق قانون التحكيم المصري، ويتم تنفيذها وفقاً لما نصت عليه المادة ٢٩٩ من قانون المرافعات التي تقرر أن "تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي" وبالتالي فإن الأصل أن يتم تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقاً لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية المنصوص عليها في قانون المرافعات (المواد من ٢٩٦ حتى ٢٩٨)، وذلك من خلال تقديم طلب الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

⚖ **غير أن المشرع قد خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات التي تنص على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يدخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد حتى ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.**

⚖ لما كانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمعروفة باسم "اتفاقية نيويورك ١٩٥٨".

⚖ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩م، وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ١٩٥٩/٦/٨م، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أي قانون آخر بمصر.

⚖ قد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن **تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمّر بتنفيذه** طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية. ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تُفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين"، ومقتضى ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها. والمقصود بعبارة - **قواعد المرافعات** - الواردة في الاتفاقية أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات، والقول بغير ذلك يعد تخصيص بغير مخصص.

⚖️ حيث أن قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م قد تضمن القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات " الواردة بنصوص اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨، فإذا تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء من حيث الاختصاص أو شروط التنفيذ من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. **فيكون قانون التحكيم بالتالي هو القانون الواجب التطبيق بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية** وذلك لعموم عبارة النص الواردة في الاتفاقية وبغير حاجة لاتفاق الخصوم على الخضوع لأحكام قانون التحكيم المصري لإمكانية تطبيق أحكامه.

⚖️ لما كانت أحكام المحكمين يتم تنفيذها استناداً لقانون التحكيم المصري وفقاً للمواد (٩، ٥٦، ٥٨)، حيث **يقدم طلب على عريضة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لاستصدار أمر بالتنفيذ**، ويرفق بالطلب المسندات المحددة في المادة ٥٦ من قانون التحكيم، ويصدر الأمر بالتنفيذ بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام بمصر وأن المحكوم عليه قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً. فإذا رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر بالتنفيذ، يجوز للمحكوم لصالحه أن يتظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ إلى محكمة الاستئناف ذاتها في خلال ٣٠ يوم من تاريخ صدور أمر الرفض. وفقاً لنص المادة ٥٨ من قانون التحكيم.

⚖️ **لا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات تعد أكثر شدة** إذ تجعل الأمر بالتنفيذ معقوداً للمحكمة الابتدائية من خلال دعوى ترفع بالأوضاع المعتادة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات متعددة إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، وما يترتب عليه ذلك من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً، وهي بلا ريب تعد إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم.

⚖️ **بالتالي فإنه تطبيقاً للمادة ٣٠١ من قانون المرافعات وعملاً بالنص المادة ٣ من اتفاقية نيويورك يتم تنفيذ أحكام المحكمين في مصر استناداً لقانون التحكيم المصري وفقاً للمواد (٩، ٥٦، ٥٨) على النحو المتقدم واستبعاد تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م.** وأن قواعد هذا القانون الأخير المتعلقة بالتنفيذ أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات.

اختبر نفسك

س ١ : عرف القانون الدولي الخاص مبيناً مصادره ؟

س ٢ : وضع القانون الواجب التطبيق علي الاهلية ؟

س ٣ : وضع موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف والإحالة ؟

س ٤ : اكتب في اجراءات دعوي تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر ؟

س ٥ : ما هو القانون الواجب التطبيق علي الميراث والوصية والهبة ؟

س ٦ : اكتب في مرحلة التكييف مبيناً نطاق نظرية بارتان مع التمثيل ؟

س ٧ : تكلم بالتفصيل عن نظرية الإحالة من حيث التعريف وصور الإحالة ؟

س ٨ : ما هو القانون الواجب التطبيق علي الشروط الموضوعية لإنعقاد الزواج وأثار الزواج وإنقضائه ؟

س ٩ : وضع اهمية الاعتراف بالاحكام الاجنبية مبيناً الشروط المتطلبة لتنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر ؟

س ١٠ : ما هي الموضوعات التي تندرج في نطاق الأحوال الشخصية في مصر وما هو القانون الواجب التطبيق علي الحالة والأهلية

بين مدي صحة او خطأ العبارات الاتية :

العلامة	السؤال	م
	وجود بعض اموال التركة في مصر يكفي لإختصاص المحكمة المصرية بنظر دعوي التركة وكان المورث اجنبياً؟	١-
	يكفي ان يكون المورث مصري او ان تكون التركة افتتحت بمصر لاختصاص المحكمة المصرية بنظر دعوي التركة ؟	٢-
	تخضع النفقة الزوجية لقانون الزوج وقت رفع الدعوي؟	٣-
	ياخذ المشرع المصري بالاحالة من الدرجة الاولى ويرفض الاحالة من الدرجة الثانية؟	٤-
	وفقاً لقواعد الاسناد المصرية تطبق علي اهلية الشخص الاجنبي قانون موطنه؟	٥-
	تختص المحكمة المصرية بنظر دعوي تطليق ترفعها زوجة سورية علي زوجها السوري ومقيم في مصر؟	٦-
	تطبق المحكمة المصرية علي دعوي النفقة الوقتية التي تطالب بها زوجة سورية من زوجها السوري القانون السوري؟	٧-
	تخضع اثار الزواج لقانون جنسية كل من الزوجين؟	٨-
	النفقة الزوجية تخضع لقانون القاضي المطروح امامه النزاع؟	٩-
	القانون الواجب التطبيق علي موضوع الوصية هو قانون جاسية الموصي وقت وفاته؟	١٠-
	يجوز للإجنبي الذي لم يبلغ ١٨ سنة مزاولة التجارة في مصر اذا كان قانون الدولة التي يتبعها بجنسيته يجيز له ذلك ؟	١١-
	لا تستطيع المرأة الاجنبية المتزوجة مباشرة التجارة في مصر الا بعد الحصول علي اذن بذلك من زوجها وفقاً لما ينص عليه قانون دولتها رغم ان قانون زوجها والقانون المصري لا يتطلب ذلك الاذن؟	١٢-
	تختص المحكمة المصرية بنظر دعوي عقد بيع عقار كائن في فرنسا ابرم في مصر وبين مصريين؟	١٣-
	اذا تزوج مصري بفرنسية فان الزواج يخضع للشروط الموضوعية للقانون الفرنسي ؟	١٤-
	تخضع نفقة الزوجة المصرية المتزوجة بأجنبي لقانون جنسية الزوج وقت الطلاق ؟	١٥-
	تعد نفقة الزوجية من الاثار المالية التي يرتبها عقد الزواج وتخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ؟	١٦-
	يطبق علي شكل الوصية قانون جنسية الموصي وقت الايصاء او قانون بلد الابرار ؟	١٧-
	عدم التلازم بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي شرط اساس لقيام ظاهرة تنازع القوانين؟	١٨-
	يطبق قانون موقع العقار علي العقود التي ترد علي العقار ؟	١٩-
	لا تختص المحكمة المصرية بنظر دعوي النفقة المرفوعة من امر اجنبية الا اذا كانت الام لها موطن في مصر ولا تكفي مجرد الإقامة ؟	٢٠-